中图分类号：　　密　　级：

UDC：　　本校编号：10652

西南政法大学

硕士学位论文

论文题目：行政非诉强制执行“三方合作和解”模式研究

研究生姓名：余阳慧　　学号：20140301030185

校内指导教师姓名：唐忠民　　职　　称：教授

校外指导教师姓名：　　职务职称：

申请学位等级：硕　士　　学科：法学　　专业：宪法学与行政法学

论文提交日期：2017年3月9日　　论文答辩日期：

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

硕士学位论文

行政非诉强制执行“三方合作和解”模式研究

Study on the mode of "three party cooperation and reconciliation" in administrative non litigation enforcement

作者姓名：余阳慧

指导教师：唐忠民

西南政法大学

Southwest University of Political Science and Law

中国知网 https://www.cnki.net

内容摘要

在近几年行政非诉强制执行的司法实践中，法院介入行政机关与相对人之间进行协调，促成执行和解，以合作的方式替代传统强制执行的新型执行模式正在兴起。本文结合各地法院的具体实践经验，总结出一种行政非诉执行的“三方合作和解”模式。该模式的核心在于，当司法强制执行在客观上不能或不宜进行时，以一种法院协调、当事人和解的方式达到“案结事了人和”的执行目的。该模式的构成要素具体包括先决条件、权力要件、客观要件、行为及结果要素。先决条件是指，行政机关作出的行政决定在程序上已经进入法院的司法审查阶段，且法院审查后认为该行政决定依法应当裁定准予执行；权力要件是指，行政机关对其作出的行政行为享有法律赋予的裁量权，包括作为与不作为的裁量以及如何作为的裁量。客观要件是指，行政相对人作为被执行人，客观上履行不能，既包括无财产可供执行，也包括虽有财产但不宜执行的情形。行为及结果要素是指，行政机关与相对人在法官的积极劝导下，协商一致变更原生效行政决定的权利义务关系，达成执行和解协议，使执行程序归于终结。

自生自发于中国司法实践的“三方合作和解”模式有其深刻的制度根源，行政非诉强制执行的制度目标要求法院必须在有效监督行政权力与保障行政权力有效运行之间寻求平衡，即公正与效率皆不可偏废，当现实出现不可预见的因素使得该制度所期待的应有效率出现凌空时，必然要求三方合作以调整个案的失衡状态。“三方合作和解”模式同时也是一种对现实需要的积极回应。大量的行政非诉执行案件在实践中遭遇“执行难”的困境，其中又以被执行人履行能力有限的问题最为突出。这类案件久拖不决、大量累积，已严重损害了行政机关的执法权威，也大大降低了司法执行效率、影响了承办法官的工作绩效，对“有案在身”的行政相对人也是百害无一利。这样的司法困境呼唤有效解决实际问题的新型执行模式，“三方合作和解”正是这样一种尝试。

“三方合作和解”模式符合三方共同利益，发挥积极效应的同时存在着许多弊端，如执行和解异化现象、法官对行政权行使的僭越以及和解侵蚀了对原生效行政行为的效力等。通过引导法官角色转变、确立执行和解协议的司法审查、赋予执行和解协议强制执行力以及适当扩大现行三方合作和解的适用范围，能够对“三方合作和解”模式进行有效控制，使该模式在实践中发挥其最大的效益。

中国知网 https://www.cnki.net

关键词：行政非诉强制执行；三方合作和解；履行不能；司法审查

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Accusing the enforcement of the judicial practice in recent years, the court between administrative organ and relative person to coordinate, to perform reconciliation, alternatives to traditional compulsory execution in the form of cooperation of new execution pattern is on the rise. In this paper, combined with the concrete practice of the local court experience, summed up the accusing the execution of a kind of administration pattern of "tripartite cooperation reconciliation". The core of the model is that when the judicial enforcement objectively cannot or should not be, in the form of a court, the parties, the reconciliation to the implementation of the "case" and "purpose. The model of the components including prerequisites, power factor and objective factor, behavior and results. Prerequisite is to point to, the administrative authority of administrative decision on the program already entered the stage of the court's judicial review, after review, and the court considers that the administrative decision according to law shall rule to allow the execution; , refers to the power of administrative behavior of administrative organs to its enjoy discretion endowed by law, including as not as discretion and how as discretion. , refers to the objective of the administrative relative person as the person subjected to execution, objective performance cannot, and includes no property available for execution, including with property but also shoulds not be executed. Refers to the behavior and results elements, the administrative organ and relative person under the judge's positive persuasion, agreed to change the original relationship between the rights and obligations of administrative decision, execution reconciliation agreement, bring executing programs to an end.

Authigenic spontaneously in China's judicial practice "reconciliation" tripartite cooperation mode has its deep root system, administrative accusing the enforcement of the system goal requires the court to the effective supervision of administrative power and seek a balance between ensuring the efficient operation of administrative power, namely the justice and efficiency should be ignored when reality unforeseen factors make the system efficiency of expected due volley, inevitable requirement tripartite cooperation to adjust the case imbalances. "Reconciliation" tripartite cooperation mode is also an active response to realistic needs. A large number of administrative case accusing the execution of "difficult to execute" difficulties encountered in practice, which as the person subjected to execution of the fulfillment of a limited ability to question the most outstanding. This kind of case dragged on,

中国知网 https://www.cnki.net

a large number of accumulation, has severely damaged the administrative organs of the law enforcement authority, greatly reduces the judicial execution efficiency, also affect the undertaking the work performance of the judge, for "with case" no administrative relative person also. Such judicial predicament calling, effectively solve the practical problems of the new execution mode, "tripartite cooperation reconciliation" is such an attempt.

"Tripartite cooperation reconciliation" model conforms to the three common interests and exert a positive effect at the same time there are many drawbacks, such as the execution reconciliation dissimilation phenomenon, the judge on the exercise of executive power trespass and reconciliation erodes the effectiveness of the effect of the original administrative behavior, etc. By guiding the judge role transformation, establish the judicial review of execution reconciliation agreement, gives execution settlement for compulsory execution as well as the appropriate enlarge the scope of current tripartite cooperation reconciliation, to be able to "reconciliation" tripartite cooperation model under effective control, make the model play its biggest benefit in practice.

Key words: Administrative accusing the compulsory execution; Tripartite cooperation reconciliation; Performance cannot; Judicial review

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

一、绪论 1
二、“三方合作和解”模式的内涵 10
（一）先决条件：生效行政处理决定经法院审查裁定准予执行 10
（二）权力要件：行政机关对其作出的行政行为享有职权处分权 13
（三）客观要件：行政相对人客观上履行不能 15
（四）行为及结果要素：在法官的协调下，双方达成执行和解 17
三、“三方合作和解”模式的形成原因 20
（一）制度根源：行政非诉强制执行制度的必然产物 20
（二）现实需求：三方利益一致性 24
四、“三方合作和解”模式的潜在弊端 29
（一）法官的主导地位可能导致执行和解异化 29
（二）终局性司法意见可能造成对行政权的僭越 32
（三）执行和解协议可能构成对行政行为效力的侵蚀 35
五、实现对“三方合作和解”模式的有效控制 37
（一）转变法官的角色定位，从主导走向引导 37
（二）确立对执行和解协议的司法审查 38
（三）明示执行和解协议的强制执行力 40
（四）适当扩大三方合作和解的适用范围 44
六、结语 47
参考文献 49
致　　谢 52

中国知网　https://www.cnki.net

一、绪论

（一）研究缘起

行政非诉强制执行是指，行政机关申请人民法院，对在法定期限内不申请复议、不提起诉讼又不履行行政决定的公民、法人或者其他组织，依法强制其履行义务的行为。随着我国依法治国进程的加快，各行政部门执法力度越来越大，申请人民法院强制执行的行政非诉执行案件逐年增加。根据山东莱芜中院 2015 年发布《2011-2013 年非诉行政案件司法审查报告》显示，2014 年该院受理非诉行政执行案件数量呈高位增长，创五年来新高，共受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件 392 件，同比增长 2.7 倍。[1]

不同于民商事案件的强制执行，行政非诉强制执行案件需要先由行政审判庭对作为执行依据的生效行政行为进行司法审查，并作出是否准予执行的裁定，被裁定准予执行的案件方能进入执行程序。在实践中，行政非诉执行案件的审查和执行需要耗费相当多的时间、精力，而这类案件绝大多数又是由人员编制较少的基层法院承担，再加上新《行政诉讼法》实行立案登记制后，行政诉讼案件数量飙升，使本就案多人少的基层法院更加不堪重负。

另一方面，在“执行难”的问题上，行政非诉强制执行案件比其他案件有过之而无不及。这类案件由于涉及行政管理秩序与普通违法者的实际利益，往往法律问题与事实问题互相缠绕，实质正义和形式正义彼此竞争，许多问题并不总是非此即彼，极大地挑战着司法功能的极限。在案件执行过程中被执行人的情绪往往比较激动、抵触情绪较深。执行措施过于强硬极易使矛盾加剧，不易取得良好的执行效果。尤其是当法院实施强制执行遇上不具有履行能力的行政相对人时，一边是期待尽快结案的行政机关，另一边是百般无奈的行政相对人，夹在中间的法院却无计可施。这类案件越积越多，在有的法院甚至已经成为造成行政非诉执行案件执结率低的主要原因。比如，海南省三亚市法院 2011 年裁定准予执行的案件共 21 件，其中执行完结 4 件、因下落不明无法执行的 2 件、因被执行人无履行能力而无法执行的共 15 件，占裁定准予执行案件的 71.43%，有效执

[1] 莱芜法院网：《2014 年全市法院行政案件司法审查报告》，（2015-05-11）[2016-6-29]，http://lwzy.sdcourt.gov.cn/lwzy/410648/410663/1088329/index.html

中国知网 https://www.cnki.net

结率仅为 19.04%。[2]

为了走出这种执行困境，改变法院“无能为力”的状态，一些法院在司法实务中逐渐形成了一种新的执行模式——将民事执行领域中平等民事主体间达成执行和解的私法技术引入行政非诉强制执行程序中，如以下案例：

成都市残联依法对 23 家未依法缴纳残疾人就业保障金的企业作出了行政处罚。行政决定作出后，行政相对人在法定期限不复议、不诉讼，亦不履行行政处罚义务，市残联遂向成都中院申请强制执行。成都中院立案受理后，依被申请人申请，依法组织了公开听证。听证会上，市残联与被申请人进行了全面的交流和沟通，被申请人清楚地认识到市残联作为征收主体的合法性，同时也向市残联提出因企业确有经济困难，请求给予减免处理。听证会结束后，法院通过审查相关案件，认定市残联作出的行政决定并无明显违法应当裁定准予执行，但又考虑到被申请人的实际履行能力，于是主动联系双方进行协调，既向被申请人进行说理教育，又向申请人说明由于被申请人的实际履行能力不足，案件强制执行可能性低的现实状况，劝导双方对争议进行协商处理。最终，在法院的努力下，23 个被申请人均与市残联达成了执行和解协议，并当庭履行完毕。最终，以市残联撤回强制执行申请的方式结案。[3]

从上述案例，我们可以看出法院积极发挥司法能动性，以其中立的形象介入相对强势的行政机关与相对弱势的行政相对人的之间进行协调，为双方搭建沟通交流平台，通过释法析理，让行政机关与行政相对人在充分协商的基础上，就执行的具体事项达成和解，终结案件执行。

根据各地法院司法统计以及相关调研报告，我们发现法院这种处理方式绝非偶然，本文在研究时收集到以下数据：四川省 2004 年至 2007 年，全省法院共受理行政非诉执行案件 31032 件，协调和解结案的有 1965 件。[4]湖北省恩施州下辖的利川法院 2009 年行政非诉执行收案 21 件，执结 21 件，全部为和解执结。[5]云南省沪西县人民法院 2010 年受理行政非诉执行案件 25 件，其中 13 件以和解方式处理；2011 年受理非诉行政执行案

[2] 吉红：“三亚市非诉行政执行案件审查和执行情况的实证分析”，董治良主编：《中国行政审判研究（第二辑）》，北京：法律出版社，2014 年版，第 565 页—566 页。

[3] 成都法院网：“成都中院强化执行措施有效促进残疾人就业保障金的征收”，（2007）[2016-7-1], http://cdfy.ChinaCourt.org/article/detail/2007/09/id/558810.shtm

[4] 成都中院课题组：“四川省行政案件协调和解情况的调查与思考”，（2009-06-27）[2016-7-1]，http://Cdfy.chinacourt.org/article/detail/2009/06/id/567554.shtml

[5] 郑兴才：“关于执行和解的思考及建议”，（2011-06-21）[2016-5-1]，http://www.chinacourt.org/article/detail/2011/06/id/454546.shtml

中国知网 https://www.cnki.net

件 25 件，4 件以和解方式结案。[6]山东威海经济技术开发区法院 2011 年、2012 年两年，共受理行政非诉执行案件 21 件，裁定准予执行 20 件，其中，经法院协调，申请人与被申请人达成和解协议并履行完毕的有 7 件，占执结案的 33.3%。[7]值得关注的还有浙江省绍兴市越城区人民法院，2009 年——2011 年，行政庭共执结行政非诉执行案件 483 件，以执行和解方式结案的仅有 4 件，以自动履行方式结案的为 156 件。但据该院工作人员介绍[8]，这些以自动履行方式结案的案件，大多数都由承办法官主动出面协调，促使双方和解，最终行政机关对原行政决定所确定的金钱给付义务进行了减免。这些案件实际上是以“自动履行”的结案方式掩盖了“协调和解”的本质。

本文将行政非诉强制执行的实务中，普遍存在的由法院积极协调，促使行政机关与行政相对人在实质性沟通的基础上对原生效法律文书所确定的具体内容等进行协商，通过法院、行政机关与行政相对人的共同合作，达成执行和解，使得法定的强制执行程序归于终结的现象归纳为行政非诉强制执行“三方合作和解”模式（以下简称“三方合作和解”模式）。

需要强调的是，本文所讨论的法院、行政机关与行政相对人三方合作下形成的执行和解，不能等同于我们通常所说的法院审理诉讼案件在原、被告之间所进行的“调解”。虽然在行为外观上二者似乎并无差异。但在某些方面，二者仍然有所区别。第一，当事人协商的前提不同，前者以行政行为合法有效为前提，而后者无此要求。第二，“调解”是诉讼法上发展比较成熟、规范的制度，当事人达成调解协议的，由法院制作调解书结案，调解书具有强制执行效力；而三方协商合作下形成的执行和解协议，并不是法院制作的规范法律文书，且不具有强制执行力。第三，新《行政诉讼法》虽然规定了对诉讼案件可以进行“有限调解”，[9]但并未明确非诉的行政执行案件也可以适用调解，相关的非诉行政执行司法解释也并未涉及，故在表述本文所讨论的现象时，为避免与立法相冲突，不宜将其定义为“调解”。

[6] 林芳：“利用和解方式处理非诉行政执行案件之必要”，（2014-10-27）[2016-2-1]，http://hhlxfy.chinacourt.org/article/detail/2014/10/id/1468267.shtml

[7] 王凤华：“对威海经济技术开发区法院成立两年来非诉行政案件审查执行情况的调查研究”，董治良主编：《中国行政审判研究（第二辑）》，北京：法律出版社，2014 年版，第 752 页。

[8] 周志贤，王普庆：“从现实向理想的迈进——行政非诉执行和解的反诉与重塑”，董治良主编：《中国行政审判研究（第二辑）》，北京：法律出版社，2014 年版，第 544 页。

[9] 《行政诉讼法》（2014 年修正）第 60 条：“人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。”

中国知网 https://www.cnki.net

（二）研究综述

目前学术界与实务界关于行政非诉强制执行中出现的协调和解现象的研究主要集中在以下几个方面：

1.行政非诉强制执行案件能否和解

目前学界对于行政非诉强制执行案件能够适用和解尚存争论，有的学者认为对于这类案件不能和解，如程宗璋认为，行政法律关系主体的权利义务关系由行政法律法规预先确定，当事人不能互相约定或自由选择，双方没有协商、互让互谅的可能性；而且，有效成立的行政行为有法律效力，不能随意变更或撤销；人民法院应该严格履行监督职能，不应促进、动员双方和解，以规避法律。[10]朱仕芬认为，行政机关作出的行政行为是法律、法规授予的职权，是代表国家进行行政管理的一种方式，不能随意处分或放弃。行政法律关系的主体不平等，不宜援引适用于平等主体的和解原则。另外，法院依法办理非诉行政执行案件的目的之一，是强制相对人履行义务或达到与义务履行相同的状态，如果允许在行政强制执行中双方当事人可以和解，就会削弱行政机关的行政管理职能，使公共秩序和公共利益受到损害，故法院在办理行政强制执行中，法官不能主持双方当事人之间的和解。[11]

而有的学者则认为，公权力并非一概不可处分，在行政非诉强制执行案件中，若行政权具有法律上的可处分性，那么适用和解就不存在任何问题。比如余军认为，在法律法规赋予行政主体自由裁量权的前提下，行政主体就可以与相对人在法律范围内达成协议，进行和解。[12]

还有的学者从现实需求着眼，认为行政非诉强制执行案件适用和解也并无不可。如李月恒认为，人民法院在行政机关拥有自由裁量权的行政非诉执行案件的执行过程中，组织双方当事人在行政机关自由裁量权的范围内进行和解，既有利于调动行政机关参与

[10] 程宗璋：“非诉行政执行案件不能和解浅议”，《广播电视大学学报（哲学社会科学版）》，1998 年第 2 期，第 91 页。
[11] 朱仕芬：“非诉行政执行制度研究”，《法律适用》，2001 年第 5 期。
[12] 余军：“私法纠纷解决模式在行政法上的运用——替代性纠纷解决（ADR）之理论原型、妥当性及其影响”，《法治研究》，2007 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

执行的积极性，通过双方当事人站在平等地位上协商、对话，为在行政决定作出时未充分行使陈述和申辩权的被执行人提供行使权利的机会，可以深化其对行政机关作出行政行为合法性的认识，有利于被执行人减少对申请人的抵触情绪，化解行政争议，自动履行义务。[13]

2.行政非诉强制执行中“和解”的含义

有的学者在进行研究时，给行政非诉强制执行中的“和解”作出了解释，比如裴娜认为，执行和解是指在行政强制执行阶段，行政机关及相对人双方就执行标的的全部或部分达成协议，从而使义务尽快得到履行以终结执行程序的行为。[14]根据其观点，行政强制执行阶段的执行和解是广义的，既包括行政机关自行强制执行，也包括行政机关申请人民法院强制执行。学者李哲认为，非诉行政执行中的和解是指，双方当事人主动协商、互谅互让，自愿达成和解协议，变更生效法律文书所确定的履行义务主体、标的物的一部分或全部、执行金钱的数额、履行期限、履行方式等的活动[15]。蔡武则认为，行政非诉强制执行中的和解是指在执行过程中，申请执行人与被执行人就执行标的物的一部分或全部，自愿协商，达成和解协议，申请执行人自愿撤回执行申请，从而终结执行程序的行为。[16]

另外，一些司法实务人员从创新法院工作方式的角度，对行政非诉强制执行中和解提出了见解，他们认为行政非诉强制执行中的和解是指认为在案件执行过程中，法院坚持协调疏导、情法并重、力求和解的原则，促使被执行人自愿履行生效行政决定所确定的义务。[17]

3.行政非诉执行和解的法律依据

许多学者为了论证行政非诉强制执行和解具有法律上的正当性，试图从现行规范的字里行间中寻找蛛丝马迹。如李月恒认为，2015 年 5 月 1 日起施行的《行政诉讼法》第

[13] 李月恒：“行政非诉执行案件适用和解结案的思考——兼谈对新修订《行政诉讼法》第六十条的理解”，提交“第六届河北法治论坛”的论文，河北，2015 年 6 月 30 日。
[14] 裴娜：“论行政强制执行中的执行和解制度”，《盐城师范学院学报（人文社会科学版）》，2006 年第 4 期，第 29 页。
[15] 李哲：“打破非诉行政执行不适用和解的迷局——对‘重庆最牛钉子户’案的法律思考”，(2007-09-26) [2016-10-1], http://www.chinacourt.org/article/detail/2007/09/id/267780.shtml
[16] 蔡武：“论我国非诉行政案件的执行对和谐社会的构建”，(2007-7-23) [2016-10-1], http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=8416&page=2
[17] 中国法院网：“长葛法院用科学发展观促成非诉行政执行案件和解”，(2009-04-30) [2016-9-28], http://www.chinacourt.org/article/detail/2009/04/id/356153.shtml

中国知网 https://www.cnki.net

60 条首次以“ 但书 ”的形式打破了行政案件不适用调解的大原则，规定了有限调解，这为源于诉讼不能调解的行政非诉执行案件亦不能执行和解找到了突破口，为行政机关拥有裁量权的行政非诉执行案件的和解适用提供了法律依据，打破了行政案件不能适用和解的法律现状。[18]郝静认为，《行政强制法》第 42 条所规定的“ 执行协议 ”[19]已将行政强制执行和解制度以法条的形式确定下来，即执行和解不仅适用于行政机关的自行强制执行，还可以适用于行政机关申请人民法院强制执行的情形，因此该条款是行政强制执行和解制度的实定法依据。[20]

有的学者从撤诉的角度来分析行政非诉执行和解具有规范层面的依据，如李伟认为，《行政诉讼法》第 62 条[21]规定了原告申请撤诉的情形，可以推断行政机关主动改变其生效行政行为是被法律所许可的，实质上就是赋予了原告、被告对双方之间的行政争议有“ 和解权 ”，表明行政诉讼法允许原、被告可以实施具有“ 和解 ”意义的行为。既然在行政诉讼阶段可以对生效行政行为进行协调变更的，那么在执行阶段也就应该允许行政机关与相对人之间进行和解。[22]

还有的学者援用民事诉讼法的司法解释来作为行政非诉强制执行和解的法律依据。如王小锋认为，新《行政诉讼法》第 101 条规定了法院审理行政案件可以适用《民事诉讼法》的相关规定[23]，因此法院在审理行政非诉强制执行案件时可援引《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 86 条[24]，允许行政机关与相对人自愿达成和解协议。[25]

---

[18] 李月恒，前注[13]。

[19] 《行政强制法》第 42 条：“ 实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议。执行协议可以约定分阶段履行；…… ”

[20] 郝静：“ 柔性化行政执法：行政强制执行和解制度解析与完善 ”，《广东行政学院学报》，2013 年第 6 期，第 55 页。

[21] 《行政诉讼法》第 62 条：“ 人民法院对行政案件宣告判决或者裁定前，原告申请撤诉的，或者被告改变其所作的行政行为，原告同意并申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。”

[22] 李伟：“ 建立非诉行政执行中的协调和解机制之初探 ”，(2015-09-21）[2016-10-5]，http://ahstfy.chinacourt.org/article/detail/2015/09/id/1710738.shtml

[23] 《民事诉讼法》第 101 条：“ 人民法院审理行政案件，关于期间、送达、财产保全、开庭审理、调解、中止诉讼、终结诉讼、简易程序、执行等，以及人民检察院对行政案件受理、审理、裁判、执行的监督，本法没有规定的，适用《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。”

[24] 《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 86 条: “ 在执行中，双方当事人可以自愿达成和解协议，变更生效法律文书确定的履行义务主体、标的物及其数额、履行期限和履行方式。和解协议一般应当采取书面形式。执行人员应将和解协议副本附卷。无书面协议的，执行人员应将和解协议的内容记入笔录，并由双方当事人签名或盖章。”

[25] 王小锋: “ 非诉行政执行案件中执行和解的适用认定”,(2016-11-21）[2016-12-10],http://blog.sina.com.cn/s/blog_15b76f2a00102wj4v.html

中国知网 https://www.cnki.net

4.设计行政非诉强制执行案件和解制度

学者们在论证执行和解适用于行政非诉执行案件具有可行性与必要性的基础上，纷纷提出和解的具体程序设计。比如吕彤儒认为，非诉行政强制执行和解应当成为一项包含运行机制、审查机制与救济机制在内的完备法律制度。其中，运行机制指和解的启动、进行及终结；审查机制包括审查组织、审查内容；引入有限的听证作为非诉行政强制执行和解的救济机制，具体包括听证的范围、期限及效力等。[26]刘丽琴认为，法律对于行政机关自行强制执行与申请法院强制执行两种不同的模式设定了应当遵守的法定程序，但执行和解应遵循何种程序，则属立法空白，应当借鉴民事合同的缔约程序来设计行政非诉强制执行和解从启动、参与主体、协商、签订和解协议、履行和解协议以及违约救济的一整套具体程序。[27]张维伟认为，建立我国非诉行政执行和解制度应当首先确立和解的基本原则，以此指导整个和解的过程；其次要明确适用范围与适用条件；最后指出应建立从提出和解到终结和解的具体运作程序。[28]

（三）对当前研究现状的反思

从目前掌握的文献资料来看，行政非诉执行中存在的和解现象已经引起了一定的关注，各位学者包括司法实务工作者对这个问题从不同角度进行了探究，这些研究成果对本文具有重要的参考价值，但同时也引发了笔者对当前研究现状的一些思考。

1.“和解”概念的不确定性

笔者在搜集参考资料时发现，研究者们似乎并不热衷于对行政非诉执行协调和解现象进行概念性的研究。在概念的构造问题上，大多是在借鉴“行政诉讼调解”、“行政机关自行强制执行和解”、民事诉讼法的“执行和解”等几个发展得比较完善的概念的基础上，结合协调和解的行为外观，经过分析整合界定出一个概念。这些努力有一定的价值，但存在的问题也是明显的——各种研究对象相互交织，常常出现混乱。比如没有认清行政机关与相对人之间的“自行和解”与“非诉阶段协调和解”的区别，将其混为一

[26] 吕彤儒:“非诉行政执行和解制度微探——一种功能分析的视角”,靳学军主编:《基层法院司法理念的多维构建》，北京：中国法制出版社，2013年版，第24页。
[27] 刘丽琴:“论我国的行政强制执行和解制度”，山西大学硕士论文，2015年6月，第25—30页。
[28] 张维伟:“我国非诉行政执行和解制度研究”，内蒙古大学硕士论文，2009年5月，第21—32页。

中国知网 https://www.cnki.net

谈，或者将法院个案性的说理教育劝导当事人履行义务这种创新性工作方式也纳入行政非诉执行协调和解的范畴。本文认为，造成这种研究现状的原因在于，现在协调和解概念具有较强的不确定性，目前只是一种关键词式的表达，使读者以为在执行程序中，只要包含“协调”、“和解”、“协议”等因素的行为，都是行政非诉执行协调和解，显然，这是极具误导性的。

2.“法律依据”的不可得

如前文所述，部分学者早已敏锐地发现了这种特殊的非诉行政强制执行现象，而他们之中的绝大多数人似乎更愿意从制度框架内寻找“法律依据”来论证这种特殊现象的正当性。然而，行政非诉执行协调和解本身就是一种在制度外进行探索的结果，，而非先天就是制度内的产物其产生与发展都源于实践的需要。既然如此，在现有的制度规范内就不可能找到真正的“法律依据”，即便找到，也只是研究者们通过法律解释手段让它“看起来”是而已。

研究者们讨论的法律依据主要是《行政诉讼法》第 60 条和《行政强制法》第 42 条。《行政诉讼法》第 60 条新增的“有限调解”对“法院审理行政案件一律不适用调解”的传统认识有了一定的突破，但是这种突破也仅仅只是局限于诉讼程序上[29]，而对于行政非诉执行，是否可以适用“和解”或“调解”则并未提及，笔者认为不宜对该条文进行扩充解释。

至于《行政强制法》第 42 条，“实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议”。有学者认为该条正是当前司法实务中所出现的法院协调和解行政非诉执行案件的法律依据。这种观点存在两个问题：（1）事实认知片面。没有认识清楚行政非诉执行协调和解在实践中的运作模式。只是单纯的看到行政机关与行政相对人“和解”的一面，却忽视了法院在促成双方和解的过程中所发挥的“协调”作用；（2）对法律条文的解读断章取义。该法第 2 条第 3 款明确规定行政强制执行既包括“行政机关自行强制执行”，也包括“行政机关申请人民法院强制执行”，因此有人认为以上两种执行模式均可适用“执行和解”。但法律条文从来都不是孤立存在的，对于第 42 条的正确解读应当从体系上进行把握。该条规定在“行政

[29] 江必新在解释《行政诉讼法》第 60 条时，指出该条的条文主旨是“本条是关于行政诉讼不适用调解原则及其例外的规定”；在其后的“修改要点”、“条文释义”以及“适用指引”部分都围绕“行政诉讼”进行解释说明。详见江必新，邵长茂：《新行政诉讼法修改条文理解与适用》，北京：中国法制出版社，2015 年版，第 225 页。

中国知网 https://www.cnki.net

机关强制执行程序”这一章中，而并非在总则里，且在第五章“申请人民法院强制执行”中也并未见类似规定，可见该条应当仅适用于行政机关的自行强制执行。故，将该条视为行政非诉执行协调和解的法律依据是不准确的。

另外有的学者提出，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 86 条是行政非诉执行和解的法律依据。这种观点的错误在于对法律条文含义的理解有偏差。新《行政诉讼法》第 101 条规定的是“本法没有规定的，适用《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定”，而 1999 年最高院《行政诉讼法若干问题的解释》规定的是“人民法院审理行政案件，……，可以参照民事诉讼的有关规定”。以上两种表述是不同的，按照新法，法院在符合条件的情况下，只能适用《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，该法以外的有关民事诉讼的规定并不在适用范围之内[30]，即民事诉讼的司法解释不能适用。

因此，在现行立法中欲求明确的“法律依据”来论证这种协调和解现象的正当性是不可得的。但这种努力也并非毫无意义，它证明了这一新生事物具有“制度可能性”。行政非诉执行协调和解虽然形成于法律制度之外，但却并非超然于现行法律制度，它仍然是在某些法律原则或者法律理念的指引下产生的，一旦获得法律的确认，就会成为制度内的事物。

3.制度构建的空心化

有的学者将研究的重点放在宏观的制度层面上，过于关注对协调和解制度的构建，从程序的启动到违约的救济，规划得完善、细致、全面。但本文认为，研究某一特殊现象应该首先尊重现象的发生规律，从实然角度考察这种现象是什么，思考它的发生机制，观察其运行效果，这是揭示其本质的必然之路。如果脱离现象本身的内在规律，动辄就从应然层面来“要求”这种现象“应该如何如何”，不仅所提出的建议没有针对性，而且还会使得这种看似无懈可击的制度设计失去内核。

（四）研究思路与创新点

本文通过考察各地法院审查和执行行政非诉执行案件的具体情况、大量搜集相关案

[30] 江必新，邵长茂：《新行政诉讼法修改条文理解与适用》，北京：中国法制出版社，2015 年版，第 355 页。

中国知网 https://www.cnki.net

例的基础上, 围绕这些事实信息与证据材料, 提出非行政非诉强制执行“ 三方合作和解 ”这一模式，并尝试以构成要素的方式界定其内涵。从行政非诉强制执行制度本身的内在逻辑以及回应现实需求的角度论证这种新型执行模式得以形成的深刻根源，并在此基础上，分析这种模式存在的弊端。最后，从这些弊端的治理着手，论证如何实现对“ 三方合作和解 ”模式的有效控制。

本文的创新之处在于，为研究行政非诉强制执行制度下出现协调和解的司法现象提供一种新的角度与思路，摒弃正当性讨论、功能价值分析以及制度构建的传统进路，把该问题重新放置于具体实践中进行观察，从而抽象出一种行为模式，并归纳这一模式的若干构成要素，实现从现象到规律的转变。

二、“ 三方合作和解 ”模式的内涵

“ 三方合作和解 ”模式是指, 在行政非诉强制执行过程中, 法院通过与行政相对人、行政机关的积极沟通、交流、教育、劝解工作，促使双方形成和解意愿，行政机关与相对人在自愿协商的基础上，互让互谅，就变更生效行政决定所确定的权利义务关系达成一致协议，法院据此终结案件执行程序的行为。

作为一种游离于现行法律规范与司法裁判实务之间的行为,“ 三方合作和解 ”模式与明显带有刚性色彩的传统强制执行模式不同，它为法院在行政非诉执行程序中提供了一种温和解决问题的方式。分析这样一种自生自发于实践，并已形成相对稳定行为模式的行政非诉强制执行现象，无论对完善行政非诉执行制度抑或是规范司法实践都具有重要意义。

本文认为,“ 三方合作和解 ”模式的具体内涵，包括以下几项构成要素：

（一）先决条件：生效行政处理决定经法院审查裁定准予执行

根据现行行政法律法规及相关司法解释，行政相对人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行生效行政处理决定，经行政机关催告，行政相对人仍未履行义务的，没有行政强制执行权的行政机关可以申请人民法院强制执行，并按照法律法规的规定提供相应的材料。

中国知网 https://www.cnki.net

行政处理决定进入法院司法审查阶段标志着三方关系的形成，这是三方合作和解的基础。除此之外，法院作出协调行动是否还需要具备其他条件，我们先分析一个案例：

某公司因拖欠劳动者工资，被香河县人事劳动和社会保障局立案调查，县劳社局要求其报送相关书面材料，该公司隐瞒事实真相，出具伪证，县劳社局遂依据《劳动保障监察条例》第 30 条对该公司作出罚款 20000 元的处罚决定。该公司收到该处罚决定后不复议、亦未提起诉讼，经催告仍不履行义务，县劳社局遂向香河县法院申请强制执行。法院在审查的过程中，为核实案情，向被申请人了解情况，被申请人对县劳社局认定的事实无争议，但向法院表示，现经济形势不好，拖欠劳动者工资事出有因，以公司目前的经济状况，对于 20000 元罚款承受不起。法院认为，县劳社局罚款 20000 元是在其法定裁量范围内作出，该行政行为无明显违法，依法应当裁定准予执行，但根据本案情况，被申请人欠薪并非故意，主观恶性较小，且现在不具备履行义务的能力，强制执行不能化解行政争议，该案可以通过行政机关调整其行政行为的内容或履行方式，以“和解”方式结案。经法院多次协调，被申请人充分认识了自己的错误，在此基础上，县劳社局与被申请人达成执行和解协议：被申请人当场一次性交纳 15000 元罚款，余款免交。[31]

从上述案例可以看出，法院在协调双方当事人之前有一个重要司法行为——司法审查，确认香河县劳社局作出的行政处罚决定无明显违法，依法应当裁定准予执行。可见，行政处理决定进入法院司法审查阶段只是形式要件，而实质要件则要求行政机关申请人民法院强制执行的行政处理决定无明显违法的情形。

那么，如何理解“无明显违法”，这实质上涉及的是行政非诉执行案件的司法审查标准问题。

最高院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》（法释〔2000〕8 号）第 93 条规定，合议庭应对行政行为的合法性进行审查，其第 95 条与《行政强制法》第 58 条规定了三项不予执行的情形：（1）明显缺乏事实根据；（2）明显缺乏法律、法规依据；（3）其他明显违法并损害被执行人合法权益。从以上规定可以看出，我国对行政非诉强制执行案件的审查标准是“明显违法”，当作为执行依据的行政处理决定存在“明显违法”情形时，法院应当裁定不予执行。那么，这种合法性审查和行政诉讼中的合法性审查有无差别以及如何判断行政机关是否“明显违法”，自行政非诉执行制度

[31]王秀玲：“非诉案件和解分析”，(2013-11-06）[2016-12-11]，http://xhxfy.chinacourt.org/article/detail/2012/11/id/1644304.shtml

中国知网 https://www.cnki.net

存在以来这些问题就一直争论不休。时任最高人民法院副院长的李国光大法官在全国法院行政审判工作会议上的讲话指出“要准确把握非诉具体行政行为合法性审查的‘度’。非诉具体行政行为与行政诉讼在合法性审查上应有不同的要求，不能等量齐观”。[32]

可见，上述问题在理论界或许尚有很大的讨论空间，但在目前实务界的处理方式则相对统一。人民法院对行政非诉执行中的合法性审查标准与行政诉讼中的合法性审查标准有所差别，这种差别体现在对行政机关违法程度的审查上。《行政诉讼法》第 70 条确立的是“一般违法标准”[33]，也就是说，在行政诉讼案件中，人民法院对被诉行政行为的审查，只要“违法”就应当判决撤销，没有“程度”上的要求；而在行政非诉执行案件中法院对行政处理决定的审查，一定要达到“明显违法”的程度，才可以裁定不予执行，“明显违法”与“一般违法”在违法的程度上显然是不一样的。

最高院作出这种处理有它的特殊考量。行政诉讼与行政非诉强制执行这两种制度具有本质上的差别。在行政诉讼中，法院对被诉行政行为进行司法审查是相对人行使诉权的结果，人民法院基于对行政相对人合法权益的保护，必然要对被诉行政行为进行严格的合法性审查；而在行政非诉强制执行中，相对人已丧失了诉权，行政处理决定已经生效，如果采用诉讼审查的标准，那么行政诉讼法关于起诉期限的规定也就失去了意义，其结果必然是架空了诉讼活动，导致行政诉讼的运行处于虚置状态。再者，行政诉讼与非诉执行在价值取向上的侧重点略有不同，诉讼倾向于公正而非诉执行则倾向于效率。[34]当非诉执行的审查标准等同于甚至高于诉讼标准时，从个案而言是保护了一些行政相对人的合法权益，但是由于行政效率、司法执行效率的缺失，最终的结果是个人利益和社会公共利益均不能得到有效保护。因此，以实质正义的立场要求非诉执行和诉讼采用统一的审查标准是不妥当的。湖南省高院行政审判庭张坤世副庭长曾经指出，“在赋予相对人诉权，而相对人放弃或丧失诉权的情况下，次要性或一般性的违法，不影响其执行”。[35]至于有瑕疵（如程序瑕疵、轻微违法等）的行政处理决定，目前比较规范的处理方法是裁定准予执行，同时向申请人或其上级机关指出或提出司法建议。[36]

---

[32] 李国光：“努力开创行政审判工作新局面为全面建设小康社会提供司法保障”，《最高人民法院公报》，2003 年第 2 期。

[33] 《行政诉讼法》第 70 条：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（1）主要证据不足；（2）适用法律、法规错误；（3）违反法定程序；（4）超越职权；（5）滥用职权；（6）明显不当。”

[34] 杨科雄：《行政非诉强制执行基本原理与实务操作》，北京：中国法制出版社，2014 年版，第 24 页。

[35] 张坤世：《行政诉讼机理探究与制度建构》，北京：中国政法大学出版社，2012 年版，第 215 页。

[36] 湖南省《关于审查和执行非诉行政执行案件的若干规定》第 38 条：“人民法院审查时发现申请执行的具体行政行

中国知网 https://www.cnki.net

从上述分析来看，经法院审查后，可能有两种结果：一种是认定行政处理决定“明显违法”，另外一种是确认行政处理决定没有“明显违法”。而根据现行法，前者应当依法作出不予执行的裁定，人民法院无权以个人意志予以变更或排除适用；而后者则比较复杂，虽然法院在理论上应当作出准予执行的裁定，但由于“没有明显违法”并不必然等同于“合法”，它可以有多种存在形态，如轻微违法、程序瑕疵、甚至是存在合理性问题等等，各地法院的具体处理方式不尽相同。但无论如何，法院要在双方当事人之间做协调工作，必须以行政处理决定不构成“明显违法”为前提。

（二）权力要件：行政机关对其作出的行政行为享有职权处分权

“和解”意味着双方需要作出让步、妥协，“必须以权利处分为前提，缺乏权利处分也就失去了和解的前提和基础”。[37]非诉行政强制执行阶段申请人（即行政机关）与被申请人（即行政相对人）在法院的协调下进行和解，必然也遵循这一规则，那么在这个过程中对作为执行对象生效行政行为内容的变更，就会涉及一个问题，即在行政权行使的场域是否存在协商变更行政行为的可能性，或者说，行政权与公民权的适度交易予以处分是否被允许。

传统行政法理论认为，行政权力不可处分，即行政权力的行使不得任意转让或放弃。然而，随着经济社会的不断发展，行政法学也在不断变革，曾经认为颠扑不破的理论也可能随时被推翻，正如西方刑事制度中的“辩诉交易”打破了一直占据主导地位的对抗式诉讼模式一样，公权力与私权利进行适度“交易”也并非完全不可能。在现代行政领域，行政机关享有大量的行政裁量权，行政机关可以根据情势需要综合考虑各方面因素并在裁量范围内选择适当的行政手段和方式。行政主体在裁量中的选择都是对行政职权的灵活运用，其实质就是对职权的一种处分。日本行政法学者南博方曾经指出，“关于公法上和解的对象的实体法具有强行的性质时，不能够予以处分，而在实体法全部赋予行政厅以裁量决定余地的情况下，缔结和解是可能的”。[38]据此，一方面，对于那些无裁量余地的行政行为，行政机关无权处分，不能和相对人作出协商、和解等交易行为，否

为存在瑕疵，但不存在上述第三十五条至三十七条规定的情形的，应裁定准予执行，对于具体行政行为存在的瑕疵，人民法院应向申请人或其上级机关指出或发出司法建议。”

[37]周佑勇：《行政裁量治理研究——一种功能主义的立场》，北京：法律出版社，2008 年版，第 193 页。

[38] [日]南博方，“行政诉讼中和解的法理（上）”，杨建顺译，《环球法律评论》，2001 年冬季号。

中国知网 https://www.cnki.net

则，就构成违法行政。另一方面，行政权也不是绝对不能处分的，对于行政机关行使裁量权作出的行政行为，是具有协商可能性的，可以与公民权适度交易。在行政非诉强制执行阶段，行政机关与行政相对人之间缔结和解契约是可能的，只要行政机关对双方协商的对象在法律授权范围内可裁量处理。

但行政机关享有裁量权仅仅是和解的前提，正如周佑勇教授所言，行政裁量是法律赋予行政机关可以选择判断的权力，行政机关通过裁量获得一定自行活动的空间，但要严格控制在法律授权的范围之内。[39]故而，行政机关和相对人要达成和解，必须是行政机关有裁量权，并且双方协商的结果不溢于裁量范围之外。裁量的法定范围和解的适用空间。[40]如《食品安全法》第 126 条规定“ 食品经营者未按规定要求销售食品的，由县级…… ；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款 ”当中的“ 5000 元以上 50000 元以下 ”是一个裁量幅度，行政机关可以在这个范围内确定处罚的具体数额，如行政机关最终决定处罚 20000 元, 在行政非诉执行阶段, 双方要达成和解, 变更处罚数额是可能的，因为行政机关对该处罚决定有裁量权，但双方协商的数额不得突破裁量的下限，即在 5000 元至 20000 元这个范围内双方是可以协商处理的。

实践中，在法院的协调下，行政机关与相对人和解，比较常见的让步除了对本金在法定裁量范围内作出减免外，还包括约定分阶段履行以及减免加处的罚款、滞纳金。关于约定分阶段履行,《行政强制法》第 42 条允许行政机关在实施自行强制执行时与相对人达成执行协议，执行协议可以约定分阶段履行。由此可见，法律授权行政机关在特定情形下可以与相对人约定行政法义务的分阶段履行。约定分阶段履行并不涉及义务总量的减让问题，只是行政机关基于特殊原因而给予相对人在履行期限上的豁免，这在非诉行政强制执行阶段也并无其他不同 ；关于减免加处的罚款、滞纳金, 按照《行政强制法》第 12 条，加处罚款或者滞纳金是行政强制执行的方式，在性质上属于“ 执行罚 ”。《行政强制法》第 42 条第 2 款规定“ 当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款或者滞纳金 ”，明确授权行政机关在自行执行过程中对符合条件的相对人，减免对其加处的罚款或滞纳金。胡建淼认为，加处罚款或者滞纳金是指当事人拒不履行基础决定所规定的义务时，行政执行机关依法通过罚款的方式给当事人设定或增加新的金钱给付义务，迫

[39] 周佑勇，前注[37]，第 20 页。
[40]同上注，第 195 页。

中国知网 https://www.cnki.net

使当事人履行原基础决定的行为。[41]德国公法理论将行政强制建筑在“基础行为”与“执行行为”的范畴之上,“执行行为”是对“基础行为”的执行。[42]也就是说,加处罚款或者滞纳金本身不是生效行政处理决定所确定的义务,而是在该行政处理决定的基础之上产生的新的义务,目的是迫使当事人履行原基础行政决定,在符合一定条件的情形下对其减免也是为了达到同样的目的具有合理性,这种合理性并不因是在行政非诉强制执行抑或自行强制执行中而有所差别。

(三)客观要件:行政相对人客观上履行不能

行政相对人客观上履行不能指的是,行政相对人主观上愿意履行生效行政处理决定所确定的义务,但其客观经济情况使其不具备实际的履行能力。

实践中,“三方合作和解”的案件最大的特征在于,行政相对人应当履行的义务是金钱给付的义务,对应的行政行为主要是行政处罚中的“罚款”与行政征收中的“行政收费”(最典型的是社会抚养费、残疾人就业保障金等),行政机关作出的这两类行政行为能否被全部履行依赖于相对人的实际经济状况。

事实证明,很大一部分涉及金钱给付的行政非诉执行案件在裁定准予执行后都很难执行到位。比如,三亚市法院在2009—2011年3年间,行政机关申请法院强制执行的案件共35件,执行完结8件,未执行完结27件,有效执结律仅为22.86%。未执行完结的案件中有15件是由于被执行人经济困难,不具备履行能力而无法执结,占未结案件的55.55%。[43]可见,被执行人在客观上履行不能已经成为法院执结非诉行政案件的重大难题。不仅三亚市如此,全国各地法院都普遍存在这种问题。

而在“罚款”与“行政收费”两类案件中,“行政收费”的执行难度较“罚款”更大。山东莱芜中院2014年受理行政非诉执行案件中,计生行政征收案件占41%,该中院执行局反映,此类案件执行难度大,执行效果差,执行到位率低。[44]计生行政征收,即我们常说的“超生罚款”,这类案件先由人口和计划生育局作出行政征收决定,有相应履行能力的行政相对人在有关部门的努力下往往已经履行完毕,而那些行政机关申请人

[41] 胡建淼:《行政强制法论》,北京:法律出版社,2014年版,第845页。
[42] [德]哈特穆特·毛雷尔著:《行政法学总论》,高家伟译,北京:法律出版社,2000年版,第489页。
[43] 吉红,前注[2],第566页。
[44] 莱芜法院网:《2014年全市法院行政案件司法审查报告》,(2015-05-11)[2016-6-29],http://lwzy.sdcourt.gov.cn/lwzy/410648/410663/1088329/index.html

中国知网 https://www.cnki.net

民法院强制执行的案件，基本上都是被执行人根本无可供执行的财产，往往成为法院“难啃”的“骨头案”。为解决这类案件，法院往往愿意主动协调，促使行政机关与相对人进行合作。比如以下案例[45]：

杨某根、杨某月违法生育，福建省泉州市丰泽区卫生和计划生育局依法作出征收社会抚养费189115元的行政决定，并向双方送达《征收社会抚养费决定书》。在法定期限内，双方不复议、不诉讼、亦拒绝履行征收决定。泉州市丰泽区卫计局遂申请泉州市丰泽区人民法院强制执行。法院审查后作出准予执行裁定，但查控财产时发现，两被执行人无可供执行的财产，但发现二人均有稳定工作。法院决定主动协调，向申请人泉州市丰泽区卫计局说明被执行人暂不具备履行义务的能力，但双方均有固定收入，建议申请人考虑允许被执行人分期履行。在法院主持协调下，泉州市丰泽区卫计局与两被执行人协商后达成和解协议：被执行人杨某月当场缴纳30000元，尚欠的159115元由被执行人杨某根、杨某月三年内分期偿还。经法院审查后，裁定终结本次执行程序。

计生类行政征收之所以执行难度大，主要原因是行政征收决定所确定的金额较高。二孩政策施行并未影响到社会抚养费的存废，目前各地仍然是按照自己标准征收社会抚养费。以重庆市为例，2016年新修订的《重庆市人口与计划生育条例》第43条规定，社会抚养费的征收标准为按照男女双方户籍所在地区县（自治县）上年居民人均可支配收入的二至三倍。[46]根据重庆市渝北区政府公布的统计数据，2015年渝北区居民人均可支配收入为27194元。按照这个标准计算，如果户籍地均为重庆市渝北区的夫妻，2016年超生一个子女，那么其所应当缴纳的社会抚养费为108776元至163164元。即使是按照征收的下限执行，将近11万元的数额对大多数人来说很难一次性给付。因此，法院在强制执行这类案件时，促成行政机关与相对人之间达成和解，使案件尽快了结，就显得很有必要了。

根据现行法律法规的规定，有的行政收费的具体数额是固定的，有的则是可变动的，对于法律规定了确定征收数额的行政收费，因为行政机关无裁量权，故这类案件不能和解。而对于具体数额可变的行政收费，如社会抚养费，其征收标准一般是一个倍数区间，

[45] 中国裁判文书网：《福建省泉州市丰泽区人民法执行裁定书（2016）闽0503执1号》，[2016-6-30]，http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=f6dcf417-c8d2-456e-9763-990fbfffce6f&KeyWord=%E6%89%A7%E8%A1%8C%E5%92%8C%E8%A7%A3

[46] 《重庆市人口与计划生育条例》第43条：“不符合再生育条件，违反计划生育法律法规生育子女的，应当按照以下规定对男女双方分别征收社会抚养费：(一)按照当事人生育行为发生时，政府统计机构公布的其户籍地所在区县(自治县)上年居民人均可支配收入的二至三倍征收社会抚养费……”

中国知网 https://www.cnki.net

具体征收数额由行政机关在区间范围内自行裁量，也就是说，这个区间内与相对人协商和解是不存在问题的。不过，这类案件在行政非诉执行的司法实践中，一般很少存在“减免”的和解，大多都是在履行期限上进行协商，如缓交、分期履行等。这主要是考虑到社会抚养费是一种行政征收，而非行政处罚，征收社会抚养费不是为了惩罚超生对象，是为了因超生子女增加社会公共投入所作的补偿，因此社会抚养费的征收涉及公共利益，法院与行政机关从维护公共利益的角度出发，很少同意相对人的“减免”请求。

如何避免作为客观事实的被执行人“履行不能”演化成法院的主观判断？如何避免被执行人为逃避执行，事先转移或隐匿财产的情况发生？在信息技术日新月异的今天，这些问题都已经得到了解决。2014 年最高人民法院与 21 家全国性的银行业金融机构建立了“总对总”的网络查控机制，并陆续为全国 30 多个省份的 3083 家法院正式开通了该系统。另外，我国大多数地区已经建立起辖区范围内的财产与个人信息查控系统，查控的财产范围包括被执行人名下的银行存款、房地产、车辆、工商股权、证券等。这些信息化技术使得法官可以随时查询被执行人的财产状况，其实际履行能力一目了然。

（四）行为及结果要素：在法官的协调下，双方达成执行和解

不同于行政机关与相对人的自行和解，“三方合作和解”模式最显见的特征是有法官的参与，且法官对于和解的启动、和解过程的进行、以及最终执行和解协议的形成都起着至关重要的作用。

据行政非诉强制执行案件和解情况相关调查表明，部分法院对符合强制执行条件但又可通过和解避免强制执行的案件，在实践操作中通常由承办法官积极对被执行人做好释法析理工作，促使其自觉履行法定义务。若双方都有和解意愿，则将行政机关和被执行人召集在一起，进行集中协调，促使案件以和解方式解决。较为典型的是新疆维吾尔自治区于田人民法院。该法院 2015 年近 50%行政非诉执行案件通过协调和解方式得到解决。[47]还有的法院不仅主动进行协调，还积极为双方提供协调方案，若双方均予以接受，则被执行人要向行政机关承诺按照该执行协议履行义务，行政机关据此撤回强制执行申请，较为典型的是威海经济技术开发区法院。该院自 2010 年成立至 2012 年，行政非诉

[47] 中国法治网：“于田法院以多种方式执行非诉行政案件”，（2016-01-15）[2016-10-29]，http://www.cermn.com/art268124.aspx

中国知网 https://www.cnki.net

执行案件共执结 17 件，其中 7 件以协调和解结案，占执结案的 33.3%。[48]

然而笔者在搜集行政非诉强制执行裁判文书时发现，虽然实践中很多案件是由法官协调和解结案，但法官所发挥的作用却很难反映到执行裁定书上。只有极少几个执行裁定书明确表明了法官在促成和解过程中的地位，例如江苏省南京市中级人民法院（2016）苏 01 行审 68 号行政裁定书[49]“经本院主持协调，钱心会与建邺区卫计局就涉案行政处罚及加处罚款事项达成执行和解协议。”陕西省蓝田县人民法院（2011）蓝执字第 00224 号执行裁定书[50]“本院在执行蓝田县安全生产监督管理局与江苏天星高空建安防腐工程有限公司行政处罚纠纷一案中，经做工作，双方当事人达成执行和解且已实际履行完毕，使本案得以全部执结。”

此外大多数都模糊地表述为“本院在审查过程中，申请执行人与被申请执行人达成执行和解”。

通过对实际案例的考察以及相关调研报告的分析，我们发现在行政非诉执行阶段，只要法官主动介入当事人之间作出协调的案件，基本都能有效促成双方和解。法官的职业特点决定了他掌握了两套知识，一套是关于法律及其解释的专业知识，一套是关于人情、事理的日常生活知识。与此相关，法官事实上有着两套逻辑，一套是法律制度建构的逻辑，一套是解决实际问题的实用主义逻辑。[51]美国学者戈尔丁曾经指出：“法官促成和解需要一种高于‘运用法律’能力的特殊技巧”[52]，而这种特殊技巧就是法官如何在解决纠纷时通过交替运用这两套知识与逻辑引导双方朝着自己预设的方向发展。当法官有意进行协调时，申请人和被执行人虽然均有是否愿意和解的回应权，但实际上这种回应权并不单纯由他们个人控制，执行法官利用自己的两套知识与话语逻辑设法说服双方作出积极回应，通过对话达到可能的自然而然的理性解决。正如湖南高院行政审判庭法官张坤世所说的“要使对方相信，如果不选择和解，结果将会对其更为不利。……从减轻被执行人负担在内的经济性考虑，以自己适当的判断和潜在的强制力的操作对解决方案的合意进行诱导”。[53]

---

[48] 王凤华，前注[7]，第 752 页。

[49] 中国裁判文书网：《江苏省南京市中级人民法院行政裁定书（2016）苏 01 行审 68 号》，[2016-9-1]，http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=dfcb3079-b381-4960-9267-9103aa3abe4e

[50] 中国裁判文书网：《陕西省蓝田县人民法院执行裁定书（2011）蓝执字第 00224 号》，[2016-9-1]，http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=198e0d1b-1270-435f-bada-43d1ec742bf8&KeyWord=执行和解

[51] 王启梁，张熙娴：“法官调解的行动逻辑”，中国社会科学报，2011 年 9 月 20 日，第 12 版。

[52] [美]戈尔丁，《法律哲学》，齐海滨译，北京：三联书店，1987 年版，第 223 页。

[53] 张坤世,前注[35]，第 168 页。

中国知网 https://www.cnki.net

既然法官有想要促成双方和解的意愿，并且也付诸实际行动了，为何在制作裁定书时又如此谨小慎微，在和解的问题上语焉不详？实际上，法官处于一个法律制度建构的场域当中，他必然要服从这一场域的规则。现在的规则是，现行行政法在行政机关自行强制执行领域有限地允许双方自行和解；而在非诉执行领域则尚未明确法院审理行政案件可通过和解的方式来解决。那么，法官为了恰当地保护自己，他就必须将他的协调和解行为制作成符合法律规定的样式——把三方合作和解的关系描述成双方和解的关系。

具体来说，在行政非诉强制执行案件中，法官的协调工作主要包括：向双方当事人说明案件情况，包括行政行为的合法性、合理性问题，被执行人的实际履行能力等；对被执行人进行说服教育，以软化其与行政机关的对立情绪；引导双方就解决执行争议的方案进行协商，或向双方提示解决争议的具体方案，促使、帮助双方达成执行协议等。

申请人与被执行人在法官的协调下，最终达成执行和解协议执行和解协议达成，标志着法院强制执行程序归于终结。该协议的内容一般涉及以下几种：(1) 原生效行政处理决定所确定义务的减免，通俗的说就是减免“本金”；(2) 行政机关所作出的执行罚的减免，即减免加处的罚款或者滞纳金；(3) 履行标的，有的案件涉及金钱义务与行为义务之间的相互转化，比如以履行某种行为义务代替金钱给付义务，但这种变更具有个案的特殊性，并不能广泛使用。比如，减免被执行人一部分残疾人保障金，并约定将减免的部分折算成被执行人应安置的残疾人就业人数；(4) 履行期限或方式，主要是暂缓履行、分阶段履行。关于实践中的执行和解协议，有几个需要说明的细节。第一，执行和解协议是否必须具有书面形式，实践中做法不一。有的案件双方约定须当场履行的，一般不会制作书面的协议书，而其他须分阶段或者暂缓履行的案件，是否制作书面协议，则依行政机关与被执行人自行协商决定。第二，当事人确需制作书面执行和解协议的，由当事人自行制作，法院不参与该协议书的制作。第三，书面执行和解协议由行政机关与被执行人签署，承办法官不以个人名义或合议庭名义签署。

中国知网 https://www.cnki.net

三、“三方合作和解”模式的形成原因

“三方合作和解”作为一种生成于传统司法强制执行制度之下的新型执行模式，其具有深刻的制度根源与潜在的现实需求。

（一）制度根源：行政非诉强制执行制度的必然产物

“三方合作和解”模式是在行政非诉强制执行制度下形成的一种特殊现象，其形成似乎与这种制度有着某种天然的联系，这种联系是什么？我们有必要对行政非诉强制执行制度做深入分析。

1.行政非诉强制执行的制度目标

我国行政非诉强制执行制度是在行政行为内容的实现因相对人既不提起诉讼又不履行而受阻的情况下，出于对滥用行政执行权的担忧及对法院有较高的信任感而形成的。[54]根据我国现行行政非诉强制执行的制度设计，梳理如下：

	相关规定	备注
审查形式	以书面审查为原则，实质审查（询问、听证）为例外	
审查标准	合法性审查，以“明显违法”为标准	
审查时限	书面审查的案件，自受理之日起 7 日内作出执行裁定；需要实质审查的案件，自受理之日起 30 日内作出是否执行的裁定。	行政诉讼则规定立案之日起 6 个月内作出第一审判决；适用简易程序审理的，立案之日起 45 日内审结。
审查结果	生效行政决定存在“明显违法”情形的，裁定不准予执行；否则，裁定准予执行	
执结时限	一般应当在立案之日起 3 个月内执结	一般的民事强制执行案件执结时限为 6 个月

通过以上梳理，我们归纳得出三个结论：

[54]傅士成：“我国非诉行政执行制度的几个问题”，《中国法学》，2002 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

第一，行政非诉执行程序强调效率。无论是“以书面审查为原则”的规定，还是明确规定的具体审查时限，都大大压缩了法官办案的时间，即要求法官“速裁、速执、速结”。行政非诉执行程序不同于行政诉讼程序，行政诉讼程序侧重于对公民权利的救济，而行政机关申请人民法院强制执行的目的在于督促行政相对人对生效行政决定所确定的义务予以实现。当行政机关申请人民法院强制执行时，行政相对人已丧失复议、诉讼等救济权利，此时，行政机关为了使本该被履行而迟迟未被履行的生效行政决定得到实际履行，维护执法权威，必然要求法院提高审查执行效率。

第二，行政非诉执行程序强调公正。将“实质审查”作为书面审查的例外规定，意味着法官通过书面审查无法核实案情时，可以通过正式的听证与非正式的听证（座谈会、论证会、个别访谈、实地访问等）听取各方意见，了解相关情况，实现司法审查的目的。法律之所以作出这样的安排，是考虑到目前行政执法的状况还不尽如人意，行政执法中的明显违法情况屡见不鲜。同时，有些行政相对人自我保护意识淡薄，没有在法定期间提起行政救济。如果人民法院不作实质审查，就会将错就错，甚至错上加错，有损法律的公正。[55]

第三，行政非诉执行程序强调司法权监督行政权的同时，也要尊重行政权。行政非诉执行确立了“明显违法”的司法审查标准，不同于行政诉讼中的“一般违法”标准，这意味着法院在审查强度上对行政机关给予了更多的尊重，在非诉执行阶段，行政相对人消极地放弃复议、诉讼的救济权利，其应当为自己的放弃行为负责。所以，只要行政行为并非到了“明显违法”的地步而致使行政权被滥用，那么法院就应当对行政机关基于其行政经验做出的判断给予足够的尊重

从上述结论可以看出，我国行政非诉强制执行的制度目标又不仅仅在于监督行政权力运行，防止行政权力滥用；还在于保障行政权力的有效运行。因此，行政非诉强制执行要求司法权必须在有效监督行政权力与保障行政权力有效运行之间寻求平衡，既要避免滥用行政权力的行政决定进入执行程序，又要保证符合强制执行条件的行政决定得到实际执行。

2.制度目标的常量与变量

[55] 全国人大常委会工作委员会行政法室：《<中华人民共和国行政强制法>释义与案例》，北京：中国民主法制出版社，2011 年版，第 209——210 页。

中国知网 https://www.cnki.net

如果把“有效监督行政权力”和“保障行政权力有效运行”这两个制度目标看成是两个具体的量，那么前者是一个相对确定的常量，而后者则是一个不确定的变量。

“有效监督行政权力”是一个常量是指，通过实定法的具体规定，“有效监督行政权力”是可以被实现的。之所以说“有效监督行政权力”是一个常量，是从制度本身进行考虑的。行政非诉强制执行制度的内在逻辑是，人民法院通过司法审查程序对行政机关作出的生效行政决定进行审查，并据此作出准予执行或不予执行的裁定，从而实现对行政权力运行的有效监督。从这个逻辑来看，影响行政权力监督有效性的因素主要在于司法审查程序，而司法审查程序最核心的内容是审查标准，也就是说，“有效监督行政权力”是一个定量还是变量，就取决于司法审查标准是一个定量还是变量。《行政强制法》已对行政非诉强制执行的司法审查标准予以设定（尽管现行的“明显违法”标准具有抽象性，但各地法院根据制度精神以及相关司法经验已经出台若干规定对该标准予以具体化，在一定程度上已经弱化了其抽象性），这意味着该审查标准的适用与否、如何适用均不以人的意志为转移，即司法审查标准具有相对确定性，因此“有效监督行政权力”的制度目标也是相对确定的。

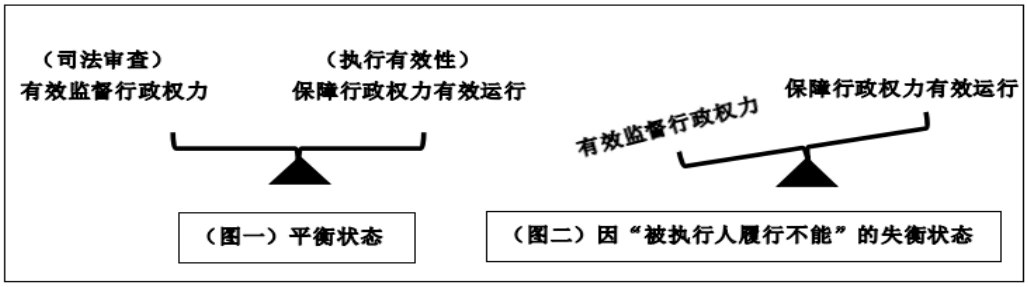
“保障行政权力有效运行”是一个变量是指，即使存在实定法的具体规定，法院仍然有可能难以实现“保障行政权力有效运行”。人民法院要保障行政权力有效运行，就必然要使那些应当被执行的生效行政决定得到有效履行，换句话说，行政权力运行有效性取决于法院强制执行的有效性。实践中，影响执行有效性的因素有很多，比如法院怠于执行、被执行人恶意逃避、被执行人履行不能等等。根据相关司法调研报告显示，当前人民法院很大一部分行政非诉强制执行案件无法执结的原因在于被执行人履行能力有限。因此，被执行人是否具备充分的履行能力直接影响了执行的有效性，从而决定了行政权力能否有效运行。行政权力运行的有效性随着被执行人实际履行能力的变化而变化。其中，被执行人的实际履行能力是自变量（独立变量），而行政权力运行的有效性则是因变量（依赖变量），即被执行人的实际履行能力越强，行政权力运行的有效性就越强；反之，被执行人的实际履行能力越弱，行政权力运行的有效性就越弱。

3.由目标变量引发的制度失衡

我们在上文已经论述，行政非诉强制执行的制度目标有两个，一个是有效监督行政权力，另一个是保障行政权力有效运行，而司法权必须在二者之间寻求平衡。对于个案

中国知网 https://www.cnki.net

来说，当“有效监督行政权力”目标是一个相对确定的常量时，行政非诉强制执行制度是处于一种平衡的状态还是处于失衡的状态，取决于另一个目标——“保障行政权力有效运行”是否能被有效实现。当行政权力运行有效性依赖于法院执行有效性，法院执行有效性又依赖于被执行人的实际履行能力时，该目标能否实现直接取决于被执行人的实际履行能力。一般情况下，当被执行人不仅具备履行生效行政决定所确定义务的能力，而且已实际履行完毕，那么此时行政非诉强制执行就处于平衡状态，如图一所示。但当被执行人不具备相应的履行能力时，法院便遭遇“执行不能”（客观条件下无法执行的案件，人民法院穷尽法律规定的一切手段和措施，均无法执结），致使行政管理目标难以实现，行政权运行受阻，此时行政非诉强制执行制度就处于失衡的状态，如图二所示。



“被执行人履行不能”是现实社会不可避免的因素，由此导致法院“执行不能”的问题也不可能依靠制度来解决。那么，如何修复这种失衡状态，笔者认为我们需要回归制度本身进行思考。根据上文论述，被执行人的实际履行能力是自变量，法院执行有效性是因变量，要使得法院的执行有效性增强，就只有增强被执行人的实际履行能力。然而，在事实上，被执行人的实际履行能力是不可变的，那么就只能反向地由行政机关减轻其所课予被执行人的负担，使之与被执行人的实际履行能力相适应。但从实际情况出发，行政机关在行政非诉强制执行阶段很难主动减轻被执行人的负担，此时司法权为恢复行政非诉强制执行制度的平衡状态，必然需要介入进来协调，行政机关与被执行人在有意无意之间就形成了一种协商、让步。

可见，“三方合作和解”并非原生于制度之内，也并非完全溢于制度之外，它实际上是当前我国行政非诉强制执行制度在具体实践中运行所出现的必然结果。这种结果由两种因素共同促成，一是行政非诉强制执行本身所固有的制度目标，要求司法权要在有效监督行政权力与保障行政权力有效运行之间寻求平衡；二是现实中无可避免的被执行人履行能力有限的问题，将导致该制度在理论上可达到的平衡状态受到破坏，由此决定

中国知网 https://www.cnki.net

了法院、行政机关以及相对人必须通过协商、让步来寻求解决问题的办法。简单而言，即在“应当强制执行”但又“无法强制执行”的矛盾中，“三方合作和解”就产生了。

（二）现实需求：三方利益一致性

在现行法不存在相关规定的情况下，法院通过介入双方之间进行协调，促成和解，终结执行程序，在事实上有效化解争议，日本行政法学者盐野宏将其称之为“实务上的智慧”。[56]然而，作为一种自生自发的非诉行政执行方式的摸索试验，三方合作的执行和解从一开始就不是法学家们倡导下的产物，而是各地法院针对非诉行政案件“执行难”的问题进行探索的结果。这种探索不是在某种理念指引下所作的改革努力，而是建立在一种利益兼得基础上的制度调整。这种调整之所以发生，是因为现行非诉行政执行制度对于各方利益的实现形成了“瓶颈效应”，以至于非通过改变这种难以适应现实状况的执行规则就不足以走出困境。无论我们事后对这种实践模式进行怎样的理论论证，都无法否认法院、行政机关与行政相对人的三方利益的一致性催生了这种“实务上的智慧”。

1.法院：实质性化解行政争议，节约执行成本

非诉行政执行案件在执行过程中执行人员需要面对的是比普通民事执行案件更加复杂的执行环境：一方面申请执行的行政机关是国家行政权力的代表，在维护行政管理秩序方面，需要法院给予更多的法律支持。另一方面作为被执行的相对人，大多情况下抵触情绪要比普通民事案件中的被执行人更深。当被执行人不具备履行能力时，实施强制执行可能出现两种情况：一是被执行人“无财产可供执行”，执行程序被迫中止，久而久之，形成大量积案；二是为了尽快结案，执行了被执行人“不宜执行”的财产（比如，被执行人有正在运营的生产设备、运营车辆、期待性财产利益等，如果此时强制执行，使得被执行人失去收入来源，甚至造成巨大损失，彻底失去偿债能力），从而引起了被执行人强烈不满，做出过激行为，不仅无法化解行政机关与相对人之间的行政争议，也影响了法院的权威，甚至危及社会稳定。

[56] [日]盐野宏：《行政法》，北京：法律出版社，1999 年版，第 369 页。

中国知网 https://www.cnki.net

此外，从法院的执行成本上考虑，当被执行人的实际履行能力不足以负担行政决定所确定的义务时，现行僵化的执行规则使得此类案件的执行不具经济性。

首先，是时间成本。法院在审查行政案件过程中可能需要组织听证[57]，实施强制执行的过程又很可能出现反复，这些都将造成时间上的拖延。其次，是直接成本。主要是指法院强制执行过程中采取的查封、扣押、拍卖等执行活动需要付出较多的人力、物力、财力等司法资源。再次，错误执行成本。法院可能随时面临因执行措施或方式失当，而被当事人申诉、信访或控告。一旦被执行人无实际履行能力，案件无法执结，也就意味着上述这些已经付出了的执行成本将无法收回。在中止执行后，若发现被执行人有财产可执行，恢复强制执行又将使法院需要付出新的一系列成本。在当前“执行难”问题未根本扭转的背景下，耗费如此大量的司法资源无疑使法院执行工作雪上加霜。

波斯纳大法官认为，法律的正义性必须以经济上的可行性、合理性为基础。[58]因此，从法经济学的角度看，不仅是法律本身的设计需要遵循经济规律，法院的执行工作同样需要考虑经济上的可行性与合理性，这意味着法院在审查、执行非诉行政执行案件时，不仅要严格遵循法律规范，还应当力求实质性化解行政争议、降低执行成本，推动形成更加科学高效的司法执行。

显然，当法院的执行工作遭遇“执行不能”的时候，无论是出于对执行效率的追求，还是实质性化解行政争议的目的，都需要法院在不违背法律原则的基础上，积极发挥司法的能动性。民事执行领域的协商和解技术正好契合了法院这一利益需求。事实证明，经法院协调，行政机关与行政相对人就执行事项达成和解，最终使案件以非强制的方式执行完毕。这种新的执行模式使得法院执行成本明显降低（不需要实施强制手段、办案时间缩短、几乎不会产生申诉、控告、上访等职业风险）、执行效率显著提高（被执行人按照执行协议自动履行）。

2.行政机关：实现管理目标，维护执法权威

行政机关基于法律的授权享有执法权，这种执法权是为了保护公民的合法权益，打击违法行为，稳定社会秩序而存在的，由此决定了行政机关针对违法行为人做出的处理

[57] 湖南省高级人民法院《关于审查和执行非诉行政执行案件的若干规定（试行）》第22条规定了10项必须举行公开听证的情形。

[58] 陈国富：《法经济学》，北京：经济科学出版社，2006年版，第285页。

中国知网 https://www.cnki.net

决定必然应当得到有效执行，否则，该处理决定就会成为“执法白条”[59]，这不但使执法机关的管理目标无法实现，而且会使公众对执法机关的信任感降低，执法权威逐渐消逝。因此，行政决定的有效实现是行政机关树立执法权威的关键性因素。基于这个考虑，行政法确立了强制执行制度，对于逾期不履行生效行政处理决定，又无正当理由的，有强制执行权的行政机关可以强制执行，无强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行。但是，这样的制度设计是否就能保障生效行政决定能够被实际执行？

事实证明，法律层面的制度设计远远跟不上千变万化的现实状况。从理论上说，经法院审查，符合执行条件的行政决定理应具有强制执行力，行政相对人应当履行相应义务，以修复因其违法行为而被破坏的社会秩序。但是，当行政相对人客观上履行该行政法义务确有困难，甚至可能当下根本不具备履行能力时，尽管法院可以作出“准予执行”的裁定并交予执行局强制执行，但后续的程序却难以顺利进行。对于申请强制执行的行政机关来说，这意味着其作出行政决定不能被实际执行，行政管理目标难以实现，执法权威受损。

行政机关迫切需要寻求摆脱这种困境的出路。考虑案件执行的协商可能性似乎可以作为治愈行政管理目标落空、执法权威受损的一剂良方。行政机关在行政过程中运用协商已经成为行政法发展的一个潮流。美国国会在《行政争议解决法》的立法原因部分明确指出，“行政程序已经变得越来越正式化、旷日持久、成本高昂，不仅耗费不必要的时间和资源，也不利于促进在合意基础上解决纠纷。而在私法领域中发展起来的协调和解技术适用于行政过程，在某些情况下可能使纠纷得到更有效、成本更小的解决，促进富有创造性和对现实更具回应性的行政。[60]从这一立法文件的正式表述中，可以看出美国立法机构对行政程序效率的热切关注。行政非诉执行作为生效行政行为在程序上的一个延伸，适用协调和解技术也并无不可。

与行政相对人进行协商和解，意味着行政机关需要作出让步——改变原行政行为，这种改变是行政机关在其自由裁量权的范围内所作出的变更，以此换取行政相对人的履行承诺。从形式上看，行政机关的这种变更实际上是对原行政决定的“打折”执行，有的学者从这点考虑，认为在行政决定生效后再进行的协商和解不具有正当性。但笔者认为这种“打折”与行政法法理并不相悖。从《行政处罚法》以及《行政强制法》等具体

[59]具有给付内容的生效行政决定不能兑现,使该执法文书变成了一纸空文。

[60] 王锡锌：“规则、合意与治理——行政过程中 ADR 适用的可能性与妥当性研究”,《法商研究》，2003 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

立法原则与精神来看，行政法的目的并不在于惩罚和强制，而是有效实施行政管理任务将处罚、强制与教育相结合，促进当事人更加主动地履行行政法律义务。行政机关通过有效沟通、平等协商，一方面，消除了行政相对人的抵触情绪，同时使其深刻认识到自身行为的违法性，达到了“教育”的目的；另一方面，在协商基础上形成的执行和解协议，通过相对人对其义务的履行作出承诺并实际履行，行政机关有效地实现了管理目标，维护了执法权威。

3.行政相对人：表达并满足自身利益诉求

在非诉行政执行案件中，作为被执行人的行政相对人与作为申请人的行政机关、以及作为执行人的法院之间，力量对比是悬殊的。当发生争议时，行政相对人往往基于弱势地位，缺乏表达利益诉求的机会和途径。这一点尤其体现在行政程序当中，尽管现代行政法已将行政行为作为一个意志沟通的过程，而不再将其仅仅当做一个纯粹单方面性的最终决定，但这种意志沟通仍旧被认为只是行政意志与相对人意志的相互融合，最终在法律上起支配力的只能是行政意志。[61]在行政机关行使裁量权做出行政决定的整个行政程序中，即便行政法赋予了相对人陈述、申辩等权利，但事实上，这些权利并不能实现行政相对人对行政裁量过程的有效参与，所谓的意志沟通只具有形式上的意义，因为相对人无法对行政决定的最终形成产生实质意义上的影响，其利益诉求无法得到表达和满足。正如以下案例：2014 年，铜川市环境保护局在一次水污染事故调查中，发现某洗煤厂未办理任何环评手续，擅自进行生产，未落实该项目“三同时”制度，且无符合标准的配套污染防治设施，简易煤水沉淀池无防渗透措施，导致煤泥水直接排入河道，严重污染水源。在事故发生后，该洗煤厂积极采取了补救措施。在处理中，铜川市环保局依法向该洗煤厂发出事先处罚告知书、处罚听证通知书，洗煤厂负责人于 7 月 19 日向铜川市环保局提出已认识到过错，且已及时采取补救措施，请求减免处罚。铜川市环保局依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十一条规定，于 2014 年 7 月 25 日作出的铜环罚字（2014）第 05 号行政处罚决定书，处罚被执行人人民币 50 万元。该洗煤厂对处罚决定表示不服。[62]

上述案例，铜川市环保局作出的行政处罚决定证据确凿、适用法律正确、符合法定

[61] 叶必丰：《行政行为的效力研究》，北京：中国人民大学出版社，2002 年版，第 50 页。
[62] 中国裁判文书网：《铜川市耀州区人民法院非诉行政执行裁定书（2015）耀新行非诉审字第 00003 号》，[2016-9-2], http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=1feaaf30-8543-4467-a354-520f5bbab42b

中国知网 https://www.cnki.net

程序，似乎并无不当。但根据《水污染防治法》第 71 条“ 建设项目的水污染防治设施未建成、未经验收或者验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的，……，处五万元以上五十万元以下的罚款 ”，铜川市环保局处罚洗煤厂 50 万元属于其行使行政裁量权的行为，在执法过程中，行政相对人已经向行政机关表示出良好的认错态度，事后也及时采取了相应的补救措施，并向环保局表达了希望可以减免处罚的诉求。根据行政法的合理性原则，行政机关行使裁量权应当在法律规定的范围内，综合考虑案件的具体情况，包括违法行为人的态度、违法行为的情节、事后的补救等因素。但在本案中，铜川市环保局作出处罚决定时并未将洗煤厂的利益诉求考虑在内，单方面作出 50 万元的处罚上限，不尽合理。

既然在行政程序中无法表达利益诉求，在强制执行阶段，行政相对人只能寄希望于法院。在非诉执行阶段，比起行政机关，行政相对人与法院之间的关系相对缓和一些。为表达自身利益诉求，有的行政相对人会主动联系法院，提出经济困难、义务履行能力有限、或者是针对违法行为已采取补救措施等理由，请求能够宽大处理。法院虽然无权代替行政机关作出决定，但可以在综合考量强制执行的必要性、可操作性与行政相对人利益诉求的基础上，通过能动司法的协调作用，为双方提供再次意志沟通的机会，而这种机会恰恰是行政相对人所需要的。通过与行政机关实质性的沟通，有效地表达了自身利益诉求，而双方意志沟通的结果——执行和解协议的形成标志着行政相对人的利益诉求不仅得到了表达，还得到了满足。

综上所述，“ 理论上应当强制执行 ”而“ 实际却执行不了 ”的非诉行政执行案件在司法实务中大量存在，长此以往，严重损害了法院、行政机关以及相对人的利益。在这样的背景下，法院、行政机关以及相对人不得不从对立走向合作，以期在处理非诉行政执行案件“ 执行难 ”的问题上，寻求一种可以实现利益兼得的行动策略。正如美国大法官波斯纳所言，市场经济条件下法官、行政主体和行政相对人均是追求利益最大化的理性人，在保护自身利益的过程中能权衡利弊作出理性决策。[63]而三方合作和解，正是这样一种三方理性选择下的行为模式。

[63] [美]理查德 · A · 波斯纳著，《法律的经济分析》，蒋兆康译，北京：中国大百科全书出版社，1997 年版，第 3——4 页。

中国知网 https://www.cnki.net

四、“三方合作和解”模式的潜在弊端

从上文的分析来看，三方合作和解模式有利于实质性化解行政争议、节约执行成本，实现行政管理目标、维护执法权威，表达、满足行政相对人自身利益诉求，并契合行政强制执行的制度原则等，有其合理性并带来了多方面的益处，但与此同时其运行也有其潜在的弊端不可忽视。

（一）法官的主导地位可能导致执行和解异化

从理论上说，法官在行政非诉强制执行程序中的职责是行使有限的审查权与执行权，目的在于实现生效行政决定确定的内容，而不是确认或者变更当事人之间的权利义务关系[64]。然而，目前的司法实践却是，大多数变更了当事人之间权利义务关系的行政非诉执行和解的背后都存在有法官的推动作用。当然，我们并非反对法官在执行阶段的地位从消极被动向积极主动转变，因为制度的运作并非总是循规蹈矩的[65]，如果某些制度外的操作策略能带来更高的效率和更好的效益，适度规避正式制度、尝试采取制度外的方式处理问题也并无不可。当法官能够通过其主动协调行动更好地实现行政非诉强制执行的制度目标时，适当突破其消极被动的地位来解决实际问题本无可厚非，但是对于法官这种“主动协调”在现实中潜在的消极作用，我们也不能视而不见。

1.法官的“主导”地位与执行和解的异化现象

在法院的行政非诉强制执行案件的协调工作中，执行法官注重从实际效果出发，根据案件的具体情况采取不同的方法，通过情理法的共同作用，努力促成和解。在具体个案中，执行法官一般会利用其职业化形象，运用专业法律知识、社会规范（民俗、习惯、道德约束等）以及最终掌握裁判权力等促成和解[66]，其直接目的在于以一种高效率、低成本、低风险的方式终结强制执行程序，真正实现案结事了人和。比起强制执行，法官更愿意以一种积极的姿态介入行政机关与相对人之间的关系，利用一切可能的手段引导

[64] 马雪涛，庄鑫斌：“行政强制执行和解司法审查制度构建相关问题研究——兼谈《行政强制法》第四十二条的完善”，董治良主编：《中国行政审判研究（第二辑）》，北京：法律出版社，2014 年版，第 320 页。
[65] 吴英姿：“司法过程中的‘协调’——一种功能分析的视角”，《北大法律评论》，2008 年第 2 期，第 495 页。
[66] 张坤世，前注[35]，第 157 页。

中国知网 https://www.cnki.net

双方进行和解，直至达成一致意见，实质性解决双方的纠纷。但由于“协调”本身无程序，甚至具有反程序的特征，法官的主动性使得协调很容易打上法院利益偏好的烙印，比如便利执行、降低执行风险、提高结案效率等。所以，在有的时候，这种“主动协调”与其说是法官对双方当事人达成执行和解一种“引导”，毋宁说是他综合运作权力和法律知识对双方进行的“威压”或“说服”。法官协调的主动性俨然已经使他在今后可能形成的三方合作关系中确立起一种近乎“主导”的地位。

由于缺乏制度性的约束，以及执行和解的高效能诱惑，执行法官的主导地位可能导致其利益偏好无限弥散，最终导致执行和解异化——以和解压执行。法官出于执行效率的考量，只要被执行人能够履行其与行政机关协商后所确定的义务，那么就对该案予以“放行”，做结案处理。至于行政机关作出的减轻原金钱给付义务的决定、免除加处的罚款或者滞纳金等执行罚义务是否可能损害公共利益或他人合法权益则持放任态度，甚至为了结案，主动做行政机关的工作，迫使其放弃部分标的。这些无疑都是执行和解的异化现象。

本文认为，行政非诉执行始终以“强制执行”为常态，个案的“协调和解”仅具有个案价值，其运作逻辑应是：当法院启动强制执行遇有某种特殊原因导致执行不能时，为“摆平”当下的矛盾而作出的特殊处理，是立足于个案的“案结事了”，绝不可能因此而确立起一种行政非诉执行的普适性规则和示范效应。但上文所描述的种种弊病都在暗示着“协调和解”作为强制执行的例外，已经出现异化现象。

2.执行和解异化的原因

表面上看，执行和解异化根源在于法官对执行效率的偏好，需要继续追问的是这种偏好缘何而来？笔者认为，主要有两个原因：

第一，人少案多的司法现状。近年来，行政非诉执行案件逐年持续攀升，而从事非诉案件执行的法官数量却并无明显增加，执行法官的办案压力陡增，人少案多的矛盾越发凸显。

以岳阳市岳阳县人民法院为例，2012 年 10 月 16 日至 2013 年 10 月 15 日，受理非诉执行行政案件 233 件；2013 至 2014 年同期，受理行政非诉执行案件 404 件，同比增

中国知网 https://www.cnki.net

长 73.4%[67]，而这两年行政审判庭的审判员稳定在 4 人左右，即平均每个法官每年审查的行政非诉执行案件大约是 80 件。另外，再加上同期的行政诉讼案件，法官的办案压力可想而知。再如，作为我国首个跨行政区划法院，上海三中院于 2014 年 12 月 28 日揭牌成立。[68]据行政庭庭长张文忠法官介绍，2015 年随着新《行政诉讼法》实施，立案登记制推行，上海三中院共受理行政案件 610 件，2016 年 1 月到 8 月新收案 680 件，至 2016 年中秋节前共存案 278 件。而三中院行政审判庭仅 7 名法官，平均每人大约分配 40 件，如果不考虑新收案件，法官们在 2016 年剩下的三个月的工作日内，以两天一件的速度办案，才可能办完所有存案。然而，事实是案件数量还在不断增加，收案范围也在扩宽。[69]可见，法官超负荷运作已成常态。面对这样繁重的业务压力，法官迫切需要提高办案效率。

第二，面临绩效考核的压力。当前，各级法院基本都建立起了法官绩效考核制度，法官们都面临着一套严格的考核体系。一般来说，法官的考核分三个板块，包括效率指标、公正指标、效果指标。对于行政非诉强制执行案件而言，效率指标就是指办案天数，在审限内是否能完成对执行依据的司法审查，作出执行裁定；在执行期限内，是否能完成案件的执行工作。公正指标指案件的质量，主要是指法官对于生效行政决定的司法审查是否能有效监督行政机关的滥权行为，能否有效避免明显重大违法的行政行为流入执行程序。效果指标则包括执行风险、上访率、申诉率、控告率等。这些指标一般会被量化并写进法官的档案里，跟法官的考核业绩、晋升、立功评奖挂钩。

对于办理行政非诉强制执行案件的法官来说，执结率无疑是最重要指标。面临越来越大的业务压力以及相对严格的考核制度，执行法官不得不寻求更加高效的方法来处理执行案件。对于法官来说，协调和解就是这样的一种捷径，无程序的特征给三方合作带来了便利、几乎不存在执行风险为法官带来了良好的办案效益，而且一旦双方达成执行和解协议，执行程序即告终结，大大提高了工作效率。在这样高效能的诱惑下，执行法官越来越“青睐”协调和解，并期待其发挥百试百灵的效用，最终发展成以和解压执行

[67] 李婵娟：“关于行政非诉执行案件‘执行难’的思考”，（2014-10-27）[2016-3-29]，http://yyxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=896

[68] 2014 年 10 月，党的十八届四中全会决定，探索设立跨行政区划人民法院和检察院，办理跨地区案件。“完善行政诉讼体制机制，合理调整行政诉讼案件管辖制度，切实解决行政诉讼立案难、审理难、执行难等突出问题。”上海作为试点，很快开始了筹备工作。2014 年 12 月 28 日，上海三中院揭牌成立。2015 年 1 月 1 日起，上海三中院依法管辖以市级人民政府为被告的一审行政案件，以及以市级行政机关为上诉人、被上诉人的二审行政案件。

[69] 徐天：“上海三中院试水‘民告官’改革”，（2016-11-01）[2016-12-25]，http://shszy.hshfy.sh.cn:8080/Fy/detail.jhtml?id=10008440

中国知网 https://www.cnki.net

的异化现象，似乎可以解释为法官基于应对内（绩效考核）外（繁重的业务）压力，回应现实的一种本能反应。

然而，如果任由执行法官的利益偏好无节制地弥散，其结果必然是使得协调和解产生越来越大的“恶”，三方合作和解的结果能否达到法律效果与社会效果的统一将主要依靠协调者——法官——的素质、技巧与自律，这是相当危险的。

（二）终局性司法意见可能造成对行政权的僭越

从目前三方合作和解的司法实践来看，在大多数情况下，三方合作和解最终形成的执行和解方案是由行政机关与相对人协商而定的，承办法官一般不提供参考意见、也不参与和解协议的制作，充其量也只对双方合意形成的和解方案进行有限的审查。但在研究的过程中，笔者发现还有这样一种情况：承办法官或合议庭直接给出具体的和解意见（有的法院称之为“协调意见”），或者对当事人协商一致达成的和解方案进行部分变更形成协调和解的“司法意见”，再询问双方是否同意按照该“意见”执行。虽然双方都有同意与拒绝的权利，但是法官凭借其特殊地位，其给出的“意见”必然带有某种隐形的强制性，使得行政机关与相对人都难以拒绝。而且，法官给出的这种司法意见具有终局性意义，双方一旦允诺同意该司法意见，那么被执行人最终履行什么义务、如何履行义务都须依照该意见确定，不能再依据原来的和解方案执行。我们通过一个典型的案例[70]予以说明：

黑龙江省大庆残疾人联合会（以下简称大庆市残联）在日常工作检查中发现，大庆市新绿阳春餐饮公司（以下简称阳春公司）应依法按照其企业规模安置残疾人就业或依法缴纳残疾人就业保障金。但检查发现其既未安置残疾人就业，也未依法缴纳残疾人就业保障金。于是向其下达了催缴通知书，要求缴纳残疾人就业保障金共计133686.46元，并处1000元罚款。阳春公司在法定期间内既未申请复议又未提起诉讼，大庆市残联申请大庆高新技术产业开发区人民法院（以下简称高新区法院）强制执行。高新区法院经审查作出准予强制执行裁定。进入强制执行程序后，被执行人阳春公司向法院提出企业现在因餐饮行业受到冲击，经营不善，企业经济效益下滑，无力一次性全部履行缴费义

[70] 牛昊祺，付建国：“黑龙江大庆高新区法院调解大庆残疾人联合会与新绿阳春公司非诉执行案”，《人民法院报》，2014年12月4日，第6版。

中国知网 https://www.cnki.net

务。高新区法院遂主持协调，向大庆市残联陈明强制执行的利弊、劝导其同意与被执行人阳春公司和解。大庆市残联与阳春公司经过沟通，协商确定的和解方案为：一是将被执行人阳春公司应缴纳的残疾人就业保障金由13万余元减至10万元，分两年缴纳完毕；二是对其罚款1000元免于处罚。

对双方达成的上述和解方案，经法院审查认为，残疾人就业保障金属于被申请执行人应按照法律规定必须缴纳的规费，即使是申请执行的行政机关也无权予以减免。合议庭结合本案的实际情况，向双方当事人给出了如下司法意见：一是被执行人按照10万元一次性缴纳残疾人就业保障金并免除其并处的罚款；二是对减免的3万余元依照法定标准计算，安置相应的残疾人到企业就业。双方当事人均表示同意并当场履行，本案执结。

上述案例，大庆市残联与被执行人阳春公司在充分协商的基础上确定了和解方案，具体涉及三方面内容：减免征收的本金、免除并处的罚款，约定分期缴纳。而法官在审查和解方案后认为，残疾人就业保障金属于被执行人按照法律规定必须缴纳的规费，大庆市残联无权减免。但为了能实际解决问题，法官在部分变更原和解方案的基础上形成一份合议庭的“司法意见”：由被执行人一次性缴纳10万元，免除并处的1000元罚款，少缴的3万余元转换成安置相应数量的残疾人就业。最后，案件以双方当事人同意按照该“司法意见”执行而告终。

应当承认，本案合议庭对大庆市残联与阳春公司达成的和解方案进行审查是恰当的，也是必须的，能够有效避免行政机关为达成和解而滥用行政权力。根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税[2015]72号）第8条规定，保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。[71]由此可见，残疾人就业保障金的具体征收数额是唯一的、可确定的，行政机关无裁量空间，必须遵照执行。因此，大庆市残联确实无权对13万余元的征收本金予以减免。合议庭为了使案件得到实际解决，向当事人直接“抛出”一份“司法意见”。表面上看，这种做法似乎“一举两得”，既有效地防止了行政机关滥用权力进行和解，又能为双方提供相对稳妥地解决实际问题的具体方案。在承认这种做法具有一定“好处”的同时，我们应该要意识到它可能存在更大的隐患。

[71] 计算公式如下：保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资

中国知网 https://www.cnki.net

这种“司法意见”，将当事人双方约定的分阶段履行（分 2 年缴清）变更为一次性缴纳，并且给被执行人额外增加了一项“安置就业”的新义务，这种变更无疑是在原和解方案的基础上加重了被执行人的负担。另外，既然“和解”意味着一定程度的妥协与让步，那么对于行政机关而言，这种妥协、让步就是对其行政权力的处分。如果由法院确定具体的和解方案，或是变更当事人的和解协议从而形成某种司法意见，那么就意味着由承办法官或合议庭对行政机关“处分什么权力、如何处分”做出了实质判断，也就是说，本该由行政机关决定的事项，转而由法官“代劳”了。这种法官“代劳”是否具有正当性呢？

我国是一个实行“集权”的国家，各种国家权力最后都集中于全国人民代表大会。全国人民代表大会授权行政机关、司法机关分别行使行政权与司法权，即司法权与行政权具有“同源”的性质。但这并不意味着司法权与行政权没有界限。早在 1989 年起草《行政诉讼法（草案）》时，王汉斌副委员长就已经指出“人民法院不能代替行政机关作出决定”。可见，虽然我国不实行三权分立，但也强调行政权与司法权互不干预。但为了监督制约行政权的运行，人民法院对行政行为进行司法审查又是必要的，这就有可能涉及司法权干预行政权的问题。然而，我们必须明确，司法审查的目标是制约行政权，而不是代行行政权，司法审查之所以有存在的必要不是因为法院可以代替行政机关做最理想的事，而是因为法院可以促使行政机关尽可能不做不理想的事。[72]王名扬教授同样认为，“正如行政机关应当尊重法院的独立，不能干涉法院的职权一样，法院也应当尊重行政机关职权的范围。.....法院不能变更行政机关的决定，是尊重行政职权和司法职权互相独立的需要，也是职务分工发挥各自专长的需要”。[73]

因此，在行政非诉执行案件三方合作和解的过程中，法官必须充分尊重行政机关作出的决定，不能逾越界限擅自变更和解方案的具体内容，比如上述案例中当事人约定：补缴的 10 万元分 2 年缴纳，而合议庭最后给出的“司法意见”则是一次性（当场）缴纳，这就不具有正当性。退一步讲，即使合议庭认为和解方案存在违法情形，也只能向当事人进行释明，并对违法的部分不予同意，而不能过于积极地提出其他替代方案，因为与被执行人和解应当采取何种方案、处分何种权力、如何处分都是行政职权的范围，应当由行政机关自行判断，司法权不得干预，否则就可能出现“司法权代行行政权”的

[72] 孙笑侠：《法律对行政的控制——现代行政法的法理解释》，济南：山东人民出版社，1999 年版，第 256 页。
[73] 王名扬：“我国行政诉讼立法的几个问题”，《法学杂志》，1989 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

现象，从而导致了司法权对行政权的僭越。从目前三方合作和解的司法实践来看，这种“僭越”客观存在。

（三）执行和解协议可能构成对行政行为效力的侵蚀

根据行政行为的效力理论，行政行为的效力一般包括公定力、拘束力、确定力和执行力。[74]所谓公定力，是指行政行为除无效外，在具有正当权限的机关撤销之前，被推定为合法有效的效力。关于拘束力，陈新民先生认为，行政处分在颁布后，若非无效的行政处分，即可产生拘束相对人、原颁布机关，以及其他相关之人民与机关之效力。[75]确定力，又称既定力、不可变更力，它是禁止和克服行政行为任意性，要求行政行为稳定性、连续性和持久性的法律力量。[76]非因法定原因并经法定程序，行政机关不得随意撤销、变更已经成立并生效的行政行为。执行力，是指行政行为一经作出，其内容必须得到切实履行的效力。以上“四个力”构成了行政行为的生命，是行政行为赖以存在的重要支撑。

从行政行为效力理论进行分析，行政非诉强制执行过程中的三方合作和解，实际上就是行政机关在法官的协调行动下，选择通过与相对人协商合意的方式行使行政裁量权，改变原生效行政行为的具体内容。这实质上会造成行政机关针对行政相对人同一违法行为进行“二次裁量”的问题。在行政机关合法的先裁量行为已发生法律效力的情况下，这种变更了先裁量行为内容的“二次裁量”就可能构成对原行政行为效力的侵蚀，首当其冲的是拘束力与确定力。

行政行为的拘束力，是指行政行为成立后，其内容对有关人员或组织产生法律上的约束力，有关人员或组织必须遵守、服从。而三方合作和解恰恰破坏了这种拘束力，使得相对人在特定情形下，获得与行政机关“讨价还价”的机会，并在此基础上形成一个相对“利己”的替代性执行方案，其本质上是对原生效行政行为的“拒绝”服从。可见，三方合作和解对行政行为拘束力的侵蚀是明显的。

行政行为的确定力要求行政机关非因法定原因并经法定程序，不得随意变更或撤销

[74] 姜明安：《行政法与行政诉讼法》，北京：高等教育出版社，2011 年版，第 205——208 页。
[75] [台]陈新民：《行政法学总论》，台湾：三民书局，1997 年版，第 237 页。
[76] 于安：《德国行政法》，北京：清华大学出版社，1999 年版，第 124 页。

中国知网 https://www.cnki.net

已生效的行政行为。一般来说，行政行为的确定力只允许在三种情况下变更或撤消[77]：(1) 因相对人提起行政复议，由行政复议机关予以裁决撤消或变更；(2) 因相对人提起行政诉讼，由人民法院判决撤消或变更；(3) 因存在违法或不当，由有权机关主动予以撤消或变更，如本行政机关，上级行政机关，国家权力机关等，但必须同样遵循法定程序。然而，行政非诉执行中的三方合作和解不属于以上任何一种情况，那么此时行政机关与相对人通过协商一致改变原行政行为的具体内容，就会使得原行政行为的确定力被侵蚀。

三方合作和解使原生效行政行为发生了变更，这种变更直接导致行政行为的拘束力与确定力受到侵蚀，由此产生最为直观的现实影响是——行政机关陷入信任危机，进而削弱了行政权的社会控制功能。行政机关能有效发挥社会控制功能的原因在于，它实施社会治理的方式、手段以及对于对违法行为的一般性评价具有可预测性，人们能预见何种行为是不被允许的、通常的违法后果是什么，人们根据这种行政的可预测性选择行动方案。如果人们原本认为可预测的事物一旦变得不可预测，人们将对行政机关产生不信任感。比如，人们知道行为 A 是被禁止的，凡作出该行为通常会被处以 10 万元罚款；行政机关通过这种一般性的评价，引导人们避免作出行为 A。但如果某天，人们发现有人作出行为 A，但由于其无力负担 10 万元，最终只付出了 1000 元的代价。此时人们就会认为行为 A 是不可预测的，因为有的人被处罚 10 万元，有的人因为经济困难而得到行政机关的减轻处理，那么是不是还有可能有人不会被处罚？行政机关的信任危机由此蔓延开来，一旦行政权的行使不被公众信任，就意味着公众已经不再相信行政机关所提倡的，也不确信他所禁止的，那么在失去行为参照的情况下，人们越来越难判断什么事可为、什么事不可为，什么行为是危险的，什么行为又是相对安全的。这样，行政机关实施社会控制就会显得越来越无能为力。

三方合作和解通过行政机关对原行政行为的内容作出一定改变来换取相对人对变更后的行政行为的履行承诺，这种做法实际上是对原行政行为执行力的变更，也是对行政行为确定力和拘束力的违背。这种违背在更宽广的层面上来说，是对已存秩序（包括行政行为效力的理论秩序以及现实人们所信赖的行政可预测性）的一种破坏，稍有不慎将使得行政机关陷入信任危机，进而削弱了行政权的社会控制功能。

[77] 熊文钊：《现代行政法原理》，北京：法律出版社，2004 年版，第 273 页。

中国知网 https://www.cnki.net

五、实现对“三方合作和解”模式的有效控制

（一）转变法官的角色定位，从主导走向引导

实践中，基于法官对执行效率的强烈追求，有的三方合作和解已经出现了“以和解压执行”的异化倾向。法官协调，促成双方和解的三方合作模式逐步让位于法官凭借其裁判地位而在三方关系中占据主导地位的异化模式。正如上文所论述，当法官占据主导地位时，三方合作和解的结果能否达到法律效果与社会效果的统一将主要依靠法官的素质、技巧与自律，这无疑非常危险。因此，为了避免出现无法控制的司法风险，必须转变法官在“三方合作和解”模式中的角色定位，法官应当从主导走向引导。

首先，法官在行政非诉强制执行过程中，应当保持中立、客观的态度。中立、客观不意味着消极对待，三方合作和解仍然需要强调法官具有一定的主动性，只是主动的程度要谨慎把握，应由过分积极转变为疏通引导，坚持和解意思自治的基本原则，不以任何方式给一方当事人施加压力。法官可以积极发挥桥梁和媒介作用，为当事人提供协商对话的机会和场所，以其所具有的专业知识与司法经验，为双方解惑答疑，帮助当事人权衡利害关系。

其次，法官可以发挥一切积极的手段促成和解，但无论如何，都不应为双方提供和解的具体意见，在三方合作和解中，法官对促成和解固然起着关键性作用，但具体的和解方案仍然需要建立在行政机关与相对人自由协商的基础之上，法官不能以某种“司法意见”取代这种自由协商的合意。美国的法官们在裁判行政案件时始终坚持一种司法谦抑的态度，即法官在司法自由裁量权的范围内，基于各种原因对行政机关保持谦让与自我克制。[78]这种司法谦抑的态度对于我国行政非诉强制执行同样具有借鉴意义。我们在强调行政权不干预司法权独立行使的同时，也应该强调司法权必须尊重行政权的运行。而三方合作和解无疑涉及行政机关对行政职权的处分，从权力分立的角度来说，这种处分只能由行政机关自己行使，法官无权干涉。因此，在三方合作和解中，法官所能够行使的建议权相当有限，尤其不能像民事调解那样，可以为双方提出具体的调解方案。

最后，必须明确“强制执行”才是制度常态。三方合作和解仅仅只是法院强制执行

[78] 黄先雄：“司法谦抑论——以美国司法审查为中心”，湖南：湘潭大学博士论文，2007 年 4 月。

中国知网 https://www.cnki.net

的一种例外，是立足于个案的特殊处理，并不具有普适性。法官不能主次不分，为了提高执行效率，罔顾实际情况以及当事人意愿，一味追求和解。当案件不具备适用和解的余地时，应当移交强制执行。

法官在三方合作和解中的地位由主导走向引导，要求法官一方面应积极地从能动司法的角度出发，搭建司法权、行政权、公民权的良性沟通平台，引导行政机关与被执行人达成和解。但这种“积极引导”不应带有强制的色彩，当出现“合意贫困化”现象——任何一方无意和解时，执行法官应当终止协调。另一方面又要保持必要的克制与谦让，不能过分地将自己的意志强加于行政机关，避免对行政权的行使构成不当的干预。

（二）确立对执行和解协议的司法审查

在“三方合作和解”模式中，三方合作的最终成果体现为具有可执行性的“和解协议”（或称和解方案），但法官是否会对该和解协议的具体内容进行审查，以及审查到何种程度，司法实践仍然相当混乱。

笔者认为，法官应当对当事人达成的和解协议进行司法审查。和解意味着行政机关需要让步或者说放弃部分权力，这种“让步”或“放弃”主要体现在行政机关同意与相对人在协商的基础上对其依法作出的生效行政决定“打折”执行。公权力的行使既然可以协商，那么协商的内容和过程应受到必要的审查与监督，以防止此项权力的滥用或缺位，以及由此引发的社会管理秩序紊乱；加之，非诉行政强制执行制度设计本身包含对作为执行对象的基础行政行为进行司法审查，而达成的和解协议是对该基础行政行为的变更，因此对和解协议的审查是非诉行政强制执行制度的应有之义。比如，上文所列举的“大庆市残联与新绿阳春公司行政征收非诉执行案”，当事人在和解协议中约定的对残疾人就业保障金的减免，行政机关不存在裁量的空间，违反了法律法规的强制性规定，而且损害了公共利益，应当是无效的。如果法官不对该和解协议进行审查，就有可能会使这类无效的约定被实际履行。长此以往，必将对执法权威和司法权威造成不利的影响。

关于对和解协议的审查程度，本文认为，法官应当在充分尊重双方合意的基础上适用一种最低限度的审查标准：

第一，审查行政机关对于和解事项是否具有法律上的处分权限。判断行政机关是否具有处分权限，一般从两方面考虑：一是法律法规是否有明确授权。如《行政强制法》

中国知网 https://www.cnki.net

第 42 条规定“当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款或者滞纳金”，即相对人在违法事实发生后主动采取补救措施的，即使行政机关先前作出的行政决定属于羁束行政行为，行政机关在执行阶段仍有处分权，但仅限于减免加处的罚款或者滞纳金，不能减免处罚本金；二是行政机关对其作出的行政行为享有裁量权。比如，《海关行政处罚实施条例》第 24 条规定“伪造、变造、买卖海关单证的，处 5 万元以上 50 万元以下罚款”，当生效行政决定是给予相对人 10 万元罚款时，在执行和解阶段，海关有权在 5 万至 10 万元范围内与相对人协商确定最后执行的具体数额；在法律法规尚未明确授权行政机关对某一事项可处分时，行政裁量便成了和解的唯一前提，无裁量即无和解。比如，《个人所得税法》第 3 条第 5 项规定“稿酬所得，适用比例税率，税率为 20%”，即行政机关对稿酬税费的征收数额不享有裁量权，不得就相对人应补缴的税费进行和解。

第二，审查和解协议的内容是否存在损害公共利益及他人合法权益的情形。

日本行政法学者南博方曾经指出“具有因和解给优势的公益造成侵害之危险的情况下，和解将被限制”。[79]因此，我们认为，当行政机关与相对人协商和解的事项损害公共利益时，和解协议是非法的。公共利益，作为一个罗生门式的概念极具抽象性，如何判断和解协议是否损害公共利益，本文认为，法官对于当事人之间的和解事项是否可能损害公共利益的判断，至少应考虑以下三个方面：首先，行政机关不得放弃法定的行政管理职权。按照法律规定，行政机关负有作为义务而和解协议约定行政机关放弃该作为义务时，应当认为和解协议损害了公共利益。比如，在上述的“大庆市残联与新绿阳春公司行政征收非诉执行案”中，大庆市残联发现阳春公司未依法安置残疾人就业，亦未缴纳残疾人就业保障金的违法行为后，依法要求阳春公司补缴拖欠的规费，并且对其作出 1000 元的处罚决定。但在后来双方达成的和解方案中，却约定免除被执行人阳春公司 1000 元的金钱给付义务。根据《黑龙江省按比例安排残疾人就业规定》（黑龙江省人民政府令 1999 年第 2 号）第 17 条规定“在按比例安排残疾人就业工作中不安排残疾人就业又不缴纳残疾人就业保障金的单位，由县级以上人民政府委托残疾人联合会对单位处以 500 元以上 1000 元以下的罚款”，可见，大庆市残联的处罚决定属于行使法定职权的范围，且罚款的具体数额在法定幅度内，并未违法。但在和解过程中，在阳春公司不存在免予处罚的情形下，大庆市残联决定免除被执行人阳春公司 1000 元的罚款义务，是

[79][日]南博方，前注[39]。

中国知网 https://www.cnki.net

放弃行政管理职权的表现，无疑是损害了公共利益。其次，行政机关必须在法律、行政法规授权范围内严格履行职责，既不能超越职权违法行政，也不能在职责范围内无原则地任意行政。当行政机关对其享有裁量权的事项进行处分时，应当在法律授予的裁量范围内与相对人和解，不能超越裁量范围作出妥协。如《城乡规划法》第 64 条规定“未取得建设工程规划许可证进行建设的.....处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款”，若城乡规划部门与违法行为人在和解协议中约定按照低于该处罚条款的下限（建设工程造价 5%）执行时，即构成任意行政，损害公共利益。最后，行政机关作出的妥协不得违反比例原则。比如，综合考量个案的违法情节与危害结果，如果行政机关让步的范围和幅度明显不成比例，则可认为已违反公共利益。

另外，行政机关不得以牺牲第三人合法权益为代价，换取相对人的义务履行承诺。任何权利的行使都不得建立在损害他人合法权益的基础之上，行政非诉强制执行中的三方合作和解当然也不能例外，当和解内容涉及第三人利益时，应当征得第三人同意，否则该和解协议无效。如我国台湾地区《行政诉讼法》第 227 条第 1 款规定“第三人参加和解成立者，得为执行之名义”。

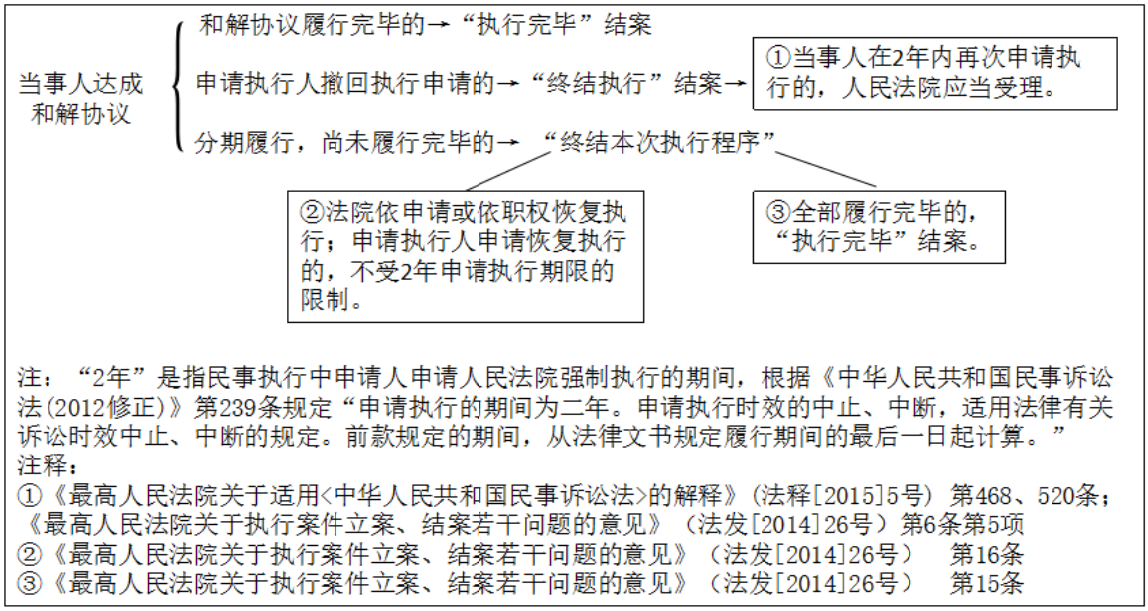
综上，在三方合作和解中，必须明确承办法官必须对当事人之间协商确定的和解协议进行司法审查，并且在充分尊重行政机关行使行政权以及当事人意思自治的基础上适用一种最低限度的审查标准，即审查行政机关对于和解事项是否具有法律上的处分权限，和解协议的内容是否可能损害公共利益及他人合法权益，若存在以上任何之一，法官应当不予同意双方按照该协议内容执行。

（三）明示执行和解协议的强制执行力

在行政非诉执行案件中，行政机关与相对人达成执行和解协议，并非就能一劳永逸，高枕无忧，要真正实现“案结事了”则依赖于双方是否能够按照和解协议约定的内容实际履行。在当前三方合作和解的实践中，“和而不解”的情况大量存在。所谓“和而不解”具体指两种情况，一种是和解协议得不到被执行人的实际履行。包括完全不履行义务以及履行部分义务后拒绝继续履行；另外一种是行政机关在达成和解协议后反悔，要求被执行人按照原行政决定履行义务，被执行人拒绝。如果不能妥善解决“和而不解”的问题，三方合作和解也将失去其应有的严肃性和实践价值。

中国知网 https://www.cnki.net

其实这种“和而不解”的问题同样存在于民事执行和解领域，为解决这一问题最高人民法院在2014年发布了《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》（法发[2014]26号），试图通过规范执行案件的结案方式来走出“和而不解”现实困境，笔者将有关执行和解的规定整理如下：



从上图我们可以看出，在民事执行领域当事人以执行和解方式结案的，法律明确赋予债权人在法院裁定“终结执行”后再次启动强制执行程序的权利，或者以“终结本次执行程序”的方式将未履行完毕的执行和解案件掌控在法院手里，以便随时依职权或依申请恢复强制执行。最高院通过规范“终结执行”与“终结本次执行程序”两种结案方式，解决了债务人在达成执行和解后又违约，致使债权人因申请期间已经过而丧失救济权的问题。

在实践中，许多法院在非诉行政强制执行的裁定中引用《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》作为裁定依据，那么，民事执行领域的成功经验能否运用到行政非诉强制执行领域，即行政非诉强制执行中“和而不解”的问题是否也可以通过规范结案方式来解决，笔者认为，不能。民事执行和解的违约问题之所以可以通过规范结案方式来解决，归根结底是因为申请民事执行的债权人申请法院强制执行的2年申请期间在性质上属于“诉讼时效”，可以存在中止、中断的情形，因此法院可以通过设定中止或中断的规则来使债权人2年的申请期间得到无限拉伸，确保债权人在执行和解协议未被完全

中国知网 https://www.cnki.net

履行的情况下，始终享有重新申请法院强制执行原生效法律文书的救济权利。然而在行政非诉强制执行中，《行政强制法》第 53 条规定，行政机关申请人民法院强制执行的期限为原生效行政决定的履行期限届满之日起 3 个月内。这里的 3 个月应当属于“除斥期间”而非“诉讼时效”，不存在时效的中止、中断问题。[80]也就是说，如果行政机关因与相对人达成和解协议而撤回申请，或者法院裁定终结本次执行程序，后因被执行人违约，行政机关需要再次申请人民法院强制执行的，必须要在 3 个月内（原生效行政决定的履行期限届满之日起算）提出，否则原生效行政决定的执行力归于消灭，除非被执行人自觉履行。这一区别决定了行政非诉强制执行三方合作和解的违约问题不可能通过类似于处理民事执行和解违约问题的手段来解决。而无论是民事执行和解还是行政非诉执行三方合作和解，当被执行人出现违约状况时，我们总是习惯性地去期待法院能够恢复执行原生效法律文书来救济守约方的权利。最高院大费周章地通过拉伸“申请期间”来帮助债权人实现这一愿望似乎也符合大众的思维定势。但当拉伸“申请期间”在行政非诉执行中变得不可能时，明示和解协议具有强制执行力也许不失为解决三方合作和解当事人违约问题的一条进路。

首先，三方合作所形成的执行和解协议具备强制执行力有其可行性。三方合作和解和行政机关与相对人之间达成的自行和解最大的区别在于，和解的过程由法院参与，法官的引导作用贯穿整个和解过程。第一，法官是和解启动的决定者。他对于具体个案是否有必要作出协调、本案在客观上是否可能和解作出具有决定性意义的判断。第二，法官是和解过程的引导者。他凭借专业知识及其司法经验积极引导双发形成和解合意，参与双方协商的全过程，确保双方能够在自愿的基础上进行利益沟通。第三，法官是和解协议的监督者。他通过对双方形成的执行和解协议进行司法审查，确保和解内容不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害国家利益、公共利益及他人合法权益，不违背善良风俗和社会公共道德。可见，从和解的启动到对和解协议的“放行”，法官从未缺席。就行为外观来看，非诉执行阶段的三方合作和解与诉讼调解其实并无二异，当新《行政诉讼法》第 94 条明确赋予了双方当事人在法院主持下达成的调解协议具有强制执行力时，赋予三方合作所形成的执行和解协议以强制执行力也应当具有可能性。

[80] 有专家对此的解释是，“行政机关申请人民法院执行其行政决定，是出于公共利益，与民事案件当事人申请法院执行是处分自己的私权利不同。为了提高行政效率，维护公共利益，行政机关应在一个不变的期间内向法院申请强制执行”。详见全国人大常委会法制工作委员会行政法室，乔晓阳：中华人民共和国行政强制法解读，北京：中国法制出版社，2011 年版，第 177 页。

中国知网 https://www.cnki.net

其次，三方合作所形成的执行和解协议具备强制执行力有其必要性。我们认为，赋予执行和解协议以强制执行力是行政管理和司法实践的现实需要。三方合作和解本质上是以当事人的合意代替强制执行，目的是以执行和解协议作为原生效行政决定的替代性履行方案促进行政管理目的的实现。作为新执行依据的执行和解协议重新调整了当事人之间的权利义务关系，从某种程度来说无异于是一个新的行政行为，又因该行政行为已经过法院的审查与认可，故理应具有强制执行力。再者，从现实情况考虑，三方合作和解何以会出现当事人随意违约的情况？归根结底在于执行和解协议对双方当事人没有强制执行力，和解协议一旦缺乏法律上的执行保障，行政相对人就会更加怠于履行义务；行政机关也很有可能在达成和解协议后反悔，在实际履行过程中要求行政相对人按照原行政决定履行义务。此外，如果不赋予执行和解协议强制执行力，而试图通过规定“一方不按和解协议履行或不完全履行的，可恢复原行政决定的强制执行”的民事手段来解决行政非诉执行案件三方合作和解中当事人违约的问题，是不现实的。不同于民事执行中申请执行人和被申请执行人为平等的民事主体，行政非诉强制执行中的申请人主要是享有行政权的行政主体而被申请人为行政相对人，二者存在天然的不平等性，一味地以“恢复原行政决定的强制执行”作为不按和解协议履行的处理方式，会不利于相对人权益的保障。并且三方合作和解的事实前提为相对人履行能力有限，和解协议本质上是对原行政决定的打折执行，相对人连打折后的义务都难以履行，更不可能希冀其有能力履行原行政决定所确定的义务。因而，无论是行政机关违约还是行政相对人违约，恢复原行政决定的强制执行，非但不能使案件有效执结，还可能大大损害行政机关的公信力以及法院的司法权威。

综上所述，要充分发挥三方合作和解的功能，达到真正的案结事了。在和解一方违反和解协议情况下，不能简单地直接挪用民事执行的相关规定将三方合作和解与民事执行和解等量齐观[81]，而应在行政非诉强制执行的场域中综合考虑。而明示三方合作和解所形成的执行和解协议的强制执行力既有利于保障行政相对人的合法权益又能更大程度上保障行政管理目的的实现，与行政非诉强制执行制度目标相契合，不失为更优的路

[81]比如某些行政非诉强制执行裁定书直接以民事诉讼相关规定作为法律依据，由此产生了许多疑问。如以“.....双方达成执行和解协议，且尚未履行完毕，本院依法裁定终结本次执行程序。.....申请恢复执行原生效法律文书的申请执行期间为二年。申请执行期间因达成执行中的和解协议而中断.....”为依据，案件性质为行政非诉执行，而恢复执行的申请期间适用的却是2年民事执行案件的申请期间，这会产生该“2年”在行政法中如何解释，以及本应是除斥期间的申请时效缘何“因达成执行和解协议而中断”的疑问。

中国知网 https://www.cnki.net

径。

（四）适当扩大三方合作和解的适用范围

“三方合作和解”模式在实践中主要适用于行政机关课予相对人金钱给付义务而相对人履行不能的案件。可以说，这样的适用范围仍然十分局限。笔者在搜集资料的过程中发现，有的案件本来也可以通过三方合作和解的方式来妥善解决，但由于这类案件在司法裁判实践中尚未形成一种通行做法，且个案的处理可能带有承办法官显见的主观判断色彩，因此大多数法官为了规避职业安全风险，不敢贸然采取三方合作和解的方式来解决执行问题。但笔者认为，既然三方合作和解的实际效用能辐射到其他类型的案件，那么当然也可以尝试将其运用到这些案件中，从而使三方合作和解产生发挥更大的效益。三方合作和解的适用范围至少应当辐射到以下两类案件：

1.生效行政决定不存在明显违法，但合理性上有瑕疵的案件

我国现行行政非诉执行确立的是“明显违法”的司法审查标准，即明显缺乏事实根据、明显缺乏法律法规依据以及其他明显损害被执行人合法权益的情形，在这一司法审查标准下，法院一般不予审查行政行为的合理性问题，这意味着法院出于对行政机关首次判断权的尊重，只要生效行政决定不属于明显违法的情形，即使承办法官认为该决定可能不尽合理，也只能裁定准予执行。然而，在这种情况下，“裁定准予执行”实在不是一个最佳的选择。我们通过一个案例[82]予以说明：

某市某合金厂是市民政局残联的集体福利企业，在一次执行政府搬迁优惠政策的过程中，民政局、残联和南排村协商租用蒙西水泥厂东荒地建厂以解决残疾人生活及就业，约定民政局、残联协助办理土地手续。后在申请办理土地使用权证时发现该租用土地早已为国土局的收储土地，为此，一直未能办理土地使用权证。国土局认为其未经批准占用城镇用地建厂，违反了《土地管理法》及《土地管理法实施条例》的相关规定，对其处以“没收新建的建筑物和其他设施，并处每平方米 30 元的罚款，共计 172781 元”。由于该企业一直不履行，国土局遂向法院申请强制执行。合议庭审查后认为，国土局的处罚决定虽未明显违法，但其处罚过重，于理不合，但又碍于行政非诉执行的司法审查

[82] 杨科雄，前注[34],第 52—53 页

中国知网 https://www.cnki.net

标准未赋予法院对合理性问题的裁判权，故对于本案是否应当裁定准予执行，合议庭难以决断。

根据《土地管理法》第76条以及《土地管理法实施条例》第42条的规定，未经批准非法占用土地的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；罚款额为非法占用土地每平方米30元以下。故国土局以30元每平方米的标准进行处罚，并不违法。但问题是，该行政决定中的处罚数额按照《土地管理法实施条例》第42条规定的罚款上限计算，确实处罚过重。首先，该合金厂并非故意非法占用土地，在建厂时已约定由民政局、残联协助办理土地使用手续，后因租用土地早已为国土局的收储土地，所以才一直未能办理土地使用权证。其次，该合金厂是市民政局残联的集体福利企业，解决了周边残疾人生活及就业的问题，具有明显的公益性质。因此，该合金厂虽然在客观上确实存在违法事实，但综合考虑本案的其他情况，按照30元每平方米进行处罚确实过重，如果准予强制执行不仅给企业带来巨大损失，而且也不利于残疾人权益保护以及社会秩序的维护，社会影响较大。

“合法但不合理”行政处罚在行政非诉执行的司法实践中并不罕见，这样的案件使得法院在审查时常常陷于准予执行与不予执行的两难境地。如果裁定准予执行，执行风险高且社会效果差；如果裁定不予执行，退回行政机关处理，那么行政机关往往会向上一级人民法院申请复议，或者重新作出类似的行政决定，前者延长了整个执行程序，而后者则使本案的执行问题又重新回到了起点，不仅对实际问题的解决毫无助益，而且还会大大降低行政效率、损害执法权威。

“三方合作和解”模式为法院破解这类难题提供了一种新的思路。法官通过其掌握的法律及解释的专业知识与关于人情事理的日常生活知识，以案外人的身份向双方陈明案件的实际情况，向行政相对人释法教育，并向行政机关析理劝导，引导双方在合意的基础上重新调整生效行政决定所确定的权利义务关系，达成执行和解，使案件在较短的时间内以双方都能接受的方式得到妥善解决。既避免了不予执行退回行政机关处理的无效率程序重复，也避免了准予执行后法院所要面临的执行风险，同时还能以一种较为温和的方式使行政机关意识到其行政行为存在的合理性瑕疵，对促进行政机关改进执法、监督其依法行政起到了重要的作用。

2.涉及行政裁决的案件

中国知网 https://www.cnki.net

行政裁决是指，行政主体作为争议双方之外的第三者按照一定的准司法程序对与行政管理活动相关的民事争议进行协调或裁决的行政行为。[83]从我国相关法律规定来看，行政裁决的适用范围包括：权属纠纷、侵权纠纷、损害赔偿争议、征收补偿争议、劳动争议、医疗事故争议、专利使用费纠纷、民间纠纷等。

从行政裁决的概念以及具体适用范围我们可以看出，行政裁决本质上是行政机关对民事纠纷的协调解决，实质争议发生在平等民事主体之间，而非行政机关与行政相对人之间，这就决定了行政裁决案件在行政非诉执行阶段具备了和解的前提和可能。大多数学者认为如果允许当事人达成执行和解来改变行政裁决结果，无异于否定了已生效的行政裁决所具有确定力。然而，正如江必新教授所言，“从法律上肯定行政裁决行为的不可变动性并无多大实际意义”[84]，既然行政机关的裁决行为本质上解决的是平等民事主体之间的纠纷，那么当民事主体之间的纠纷发生变动时，行政裁决行为也会随之变动。当民事纠纷当事人（即行政相对人与第三人）已达成和解的情况下，行政机关变更或撤销行政裁决，实际上是民事纠纷当事人对自己权利自由处分的结果，并不涉及公权力的调整减让。[85]所以，在行政非诉执行中，行政裁决案件的处理手段可以比其他行政案件更加灵活多变，而三方合作和解不失为一种优选方案。例如以下案例[86]：贾某在 A 公司工作，未与 A 公司签订书面劳动合同，A 公司亦未按规定为贾某缴纳社会保险费，贾某向市劳动局投诉。市劳动局严格按法定程序，以 A 公司未与贾某签订书面合同，亦未给贾某缴纳社会保险费为由，根据《劳动合同法》第 10 条、第 82 条第 1 款和《劳动合同法实施条例》的相关规定、《社会保险费征收暂行条例》第 2 条、第 12 条规定作出了处理决定：A 公司应支付贾某工作期间的双倍工资，并为其补缴社会保险费。市劳动局作出裁决后，A 公司在法定期限内不起诉、不复议、也不履行相关义务。市劳动局遂申请人民法院强制执行。在法院审查的过程中，被申请人 A 公司向法院提出异议：市劳动局所认定的贾某工作起始时间证据不足。法院为核实案件事实，遂主动询问申请人市劳动局与第三人贾某意见。合议庭认为，查清贾某确切的入职时间已经不可能，虽然其工作的起始时间不能完全锁定，但根据现有证据，市劳动局的认定已经是最为合理，但仍是

[83] 应松年，胡建淼，江利红：《行政法学》，北京：中国人民大学出版社，2010 年版，第 279 页。
[84] 江必新：《行政诉讼问题研究》，北京：中国人民公安大学出版社，1989 年版，第 163 页。
[85] 周佑勇，前注[37],第 210 页。
[86] 宁州平：“非诉行政执行案件和解——化解行政争议的最佳途径”，（2012-5-23）[2016-7-29]，http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=21146

中国知网 https://www.cnki.net

证据单薄，因此本案在事实认定的问题上处于准予执行和不予执行的尴尬境地，法院难以抉择。

在上述案件的审理中，法官陷入了两难：如果裁定准予执行，由于被申请执行人A公司提出的异议确实成立，被执行人必然认为法院与市劳动局“官官相护”，强制执行无疑会对行政机关的公信力以及法院的司法权威造成重大损害。如果裁定不予执行，无疑是将难题再一次踢回市劳动局，当查清贾某确切入职时间确有困难的情况下，市劳动局不可能作出更为恰当的裁决，本案极有可能成为“无头案”，不利于保护第三人贾某的合法权益。此时，三方合作和解使得法官无需在准予执行还是不予执行的两难之间作出选择，转而通过另外一种“软性”的手段处理案件，真正做到“案结事了人和”。法官的释法析理，能够使被执行人认识到自己的违法行为，也可以使行政机关了解行政管理工作中还需改进的地方，消解双方的对立情绪，缓和紧张的氛围，促进行政机关、相对人及第三人在良性互动的基础上协商，从而确定可供执行的和解方案，最后达到实质性化解争议的目的。

三方合作和解之所以可以适用于行政裁决案件，原因在于案件的实质争议是民事纠纷，平等民事主体之间本就可以通过和解来化解争议，况且行政机关、相对人及第三人达成的和解协议不涉及行政权的处分问题，因此，行政裁决案件在强制执行阶段适用三方合作和解不存在问题。

六、结语

美国学者戴维斯针对美国当时行政裁量问题未引起行政法学界的充分重视的状况，一针见血地指出“屋顶的前后两端，其中一端显然已经相当坚固了，但是大多数学者仍然蜂拥在这一端研究如何防止屋顶的渗漏；而另一边即将倒塌，却未能引起足够关注，只派一个临时工进行照看”。[87]今天，我们同样可以用这个比喻来形容我国行政非诉强制执行制度的现状：大多数学者和立法者都将目光聚焦在如何完善行政诉讼的问题上，通过各类“声势浩大”的修法活动与“层见迭出”的司法解释使得有关行政诉讼的各项规定日臻完善，但行政非诉执行却似乎并未引起重视。我国行政非诉执行的司法实践在立

[87] [美]肯尼斯·卡尔普·戴维斯：《裁量正义》，毕洪海译，北京：商务印书馆，2009年版，第3页。

中国知网 https://www.cnki.net

法与现实严重脱节、甚至“ 无法可依 ”的情境下匍匐前行。这样的艰难处境决定了法官必须凭借其禀赋[88]来解决实际问题，而三方合作和解正是我国法官禀赋的产物。

随着行政法的不断发展，德国、法国、日本、澳大利亚等国家的行政纠纷多元化解决机制方兴未艾，而一个重要趋势就是注重行政争议的协调解决[89]。“ 三方合作和解 ”模式作为一种“ 实务上的智慧 ”顺应了这种发展趋势，并在司法实践中显示了强大的效能，以柔和的方式代替硬性冰冷的强制手段，不仅推动了个案纠纷的实质性解决，而且对于促进“ 官民和谐 ”、提高司法执行效率、树立行政执法权威具有不可忽视的意义。目前“ 三方合作和解 ”模式在实践中基本适用于被执行人履行不能的情形，但该模式的内在机理决定了它具有强大的包容性，同样能适用于其他类型的执行案件，如行政行为合理性有瑕疵的案件以及行政裁决案件等等。

以此观之，“ 三方合作和解 ”模式必将获得强大的生命力。虽然“ 三方合作和解 ”模式仍然会存在一些先天固有的不可避免的弊端，如对行政权的行使造成一定的干预，可能侵蚀行政行为效力等，但只要对其中一些人为造成的弊端因素进行妥善控制这些弊端便不影响其实际效能的发挥。

[88] “ 禀赋 ”是微观经济学中的术语，按照美国经济学家哈尔·范里安的观点，禀赋是指一个经济人在我们关注其经济行为的时期开始时拥有的资源。法官当然也属于广义上的经济人，并且是极具理性的经济人，他们懂得如何在公正与效率之间实现效益最大化。本文认为，从经济学的角度来分析，“ 三方合作和解 ”模式就是一种经济行为（高效率、低风险、正收益），在“ 三方合作和解 ”模式的形成过程中，法官的禀赋表现为丰富的司法经验与优异的法律解释与适用的能力，以及突破法律陈规、进行合理改革的智慧与勇气。

[89] 耿宝建：“ 行政纠纷解决机制的多元化选择 ”，汪庆华，应星主编：《中国基层行政争议解决机制的经验研究》，上海：三联书店，2010 年版，第 244 页。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

（一）著作类

1.[美]戈尔丁：《法律哲学》，齐海滨译，北京：三联书店，1987 年版。

2.哈特穆特·毛雷尔著：高家伟译《行政法学总论》，北京：法律出版社，2000 年版。

3.应松年、胡建淼、江利红：《行政法学》，北京：中国人民大学出版社，2010 年版。

4.盐野宏：《行政法》，杨建顺译，北京：法律出版社，1999 年版。

5.陈新民：《行政法学总论》，台湾：三民书局，1997 年版。

6.于安：《德国行政法》，北京：清华大学出版社，1999 年版。

7.姜明安：《行政法与行政诉讼法》，北京：高等教育出版社，2011 年版。

8.熊文钊：《现代行政法原理》，北京：法律出版社，2004 年版。

9.江必新：《行政诉讼问题研究》，北京：中国人民公安大学出版社，1989 年版。

10.胡建淼：《行政强制法论》，北京：法律出版社，2014 年版。

11.肯尼斯·卡尔普·戴维斯：《裁量正义》，毕洪海译，北京：商务印书馆，2009 年版。

12.周佑勇：《行政裁量治理研究——一种功能主义的立场》，北京：法律出版社，2008 年版。

13.叶必丰：《行政行为的效力研究》，北京：中国人民大学出版社，2002 年版。

14.孙笑侠：《法律对行政的控制——现代行政法的法理解释》，济南：山东人民出版社，1999 年版。

15.理查德·A·波斯纳著：《法律的经济分析》，蒋兆康译，北京：中国大百科全书出版社，1997 年版。

16.陈国富：《法经济学》，北京：经济科学出版社，2006 年版。

17.杨科雄：《行政非诉强制执行基本原理与实务操作》，北京：中国法制出版社，2014 年版。

18.张坤世：《行政诉讼机理探究与制度建构》，北京：中国政法大学出版社，2012 年版。

19.江必新、邵长茂：《新行政诉讼法修改条文理解与适用》，北京：中国法制出版社，2015 年版。

20.全国人大常委会工作委员会行政法室：《<中华人民共和国行政强制法>释义与案例》，北京：中国民主法制出版社，2011 年版。

21.全国人大常委会法制工作委员会行政法室：《中华人民共和国行政强制法解读》，北京：中国法制出版社，2011 年版。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）论文类

1.[日]南博方：“行政诉讼中和解的法理（上）”，《环球法律评论》，杨建顺译，2001 冬季号。

2.关保英：“ 行政强制执行和解协议研究 ”，《法学研究》，2013 年第 8 期。

3.关保英：“ 论行政主体的职权处分权 ”，《东方法学》，2008 年第 1 期。

4.黄学贤：“ 非诉行政执行制度若干问题探讨 ”，《行政法学研究》，2014 年第 4 期。

5.余凌云：“ 论对行政契约的司法审查 ”，《浙江学刊》，2006 年第 1 期。

6.周佑勇、解瑞卿：“ 行政和解的理论界定与适用限制 ”，《湖北社会科学》，2009 年第 8 期。

7.陈瑞华：“ 刑事诉讼的私力合作模式——刑事和解在中国的兴起”，《中国法学》，2006 年第 5 期。

8.张淑芳：“ 行政强制执行中的行政让渡 ”，《社会科学辑刊》，2013 年第 5 期。

9.杨建顺：“ 行政强制中的和解——三环家具城案的启示 ”，《南通师范学院学报》，2002 年第 1 期。

10.裴娜：“ 试论执行和解制度在行政强制执行中的确立 ”，《行政法学研究》，2004 年第 4 期。

11.郝静：“柔性化行政执法：行政强制执行和解制度解析与完善”，《广东行政学院学报》，2013 年第 6 期。

12.王启梁、张熙娴：“ 法官调解的行动逻辑”，《中国社会科学报》，2011 年第 12 期。

13.吴英姿：“司法过程中的‘ 协调 ’——一种功能分析的视角”，《北大法律评论》，2008 年第 2 期。

14.余军：“私法纠纷解决模式在行政法上的运用——替代性纠纷解决（ADR）之理论原型、妥当性及其影响”，《法治研究》，2007 年第 4 期。

15.朱仕芬：“非诉行政执行制度研究”，《法律适用》，2001 年第 5 期。

16.傅士成：“我国非诉行政执行制度的几个问题”，《中国法学》，2002 年第 3 期。

17.王锡锌：“规则、合意与治理——行政过程中 ADR 适用的可能性与妥当性研究”，《法商研究》，2003 年第 5 期。

18.吕彤儒：“ 非诉行政执行和解制度微探——一种功能分析的视角 ”，靳学军：《基层法院司法理念的多维构建》，北京：中国法制出版社，2013 年。

19.黄先雄：“司法谦抑论——以美国司法审查为中心”，湘潭大学博士论文，2007 年 6 月。

20.杨朝程、钱 昕：“ 关于行政非诉执行案件和解情况的分析——以基层法院相关调查为据 ”，《法制与社会》，2012 年 11 月（上）。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）其他类

1.莱芜法院网：《2014 年全市法院行政案件司法审查报告》，2015 年 5 月 15 日，http://lwzy.sdcourt.gov.cn/lwzy/410648/410663/1088329/index.html

2.中国裁判文书网：《福建省泉州市丰泽区人民法执行裁定书（2016）闽 0503 执 1 号》，2016 年 6 月 30 日,http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=f6dcf417-c8d2-456e-9763-990fbfffce6f&KeyWord=%E6%89%A7%E8%A1%8C%E5%92%8C%E8%A7%A3。

中国裁判文书网：《江苏省南京市中级人民法院行政裁定书（2016）苏 01 行审 68 号》2016 年 9 月 1 日，http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=dfcb3079-b381-4960-9267-9103aa3abe4e。

中国裁判文书网：《陕西省蓝田县人民法院执行裁定书（2011）蓝执字第 00224 号》，2016 年 9 月 1 日，http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=198e0d1b-1270-435f-bada-43d1ec742bf8&KeyWord=执行和解。

5.中国裁判文书网：《铜川市耀州区人民法院非诉行政执行裁定书（2015）耀新行非诉审字第 00003 号》，2016 年 9 月 2 日 http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=1feaaf30-8543-4467-a354-520f5bbab42b。

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

论文从选择题目、开题报告的撰写、论文的具体写作再到最终定稿，我的导师唐忠民老师都给予了精心指导和悉心关怀，为本文的顺利完成倾注了辛勤汗水。导师严谨的治学态度、渊博的知识、无私的奉献精神，也使我深受感染。从尊敬的导师身上，我不仅学到了扎实的专业知识，也学会了做人的道理。在西南政法大学行政法学院三年的研究生学习生活中，除了导师唐忠民教授外，陆伟明老师也给予了我学习和生活无微不至的指导和关怀。在此，我向我的导师唐忠民教授、陆伟明教授致以真诚的感谢与祝福！

同时，我还要感谢同门的各位同学好友，在三年研究生生涯的科研以及学习生活中给予我许多鼓励和帮助。

最后，感谢培养我长大，伴我成长的家人。是你们的爱护、包容、理解与支持，筑起了我坚强的后盾。

中国知网 https://www.cnki.net